

從經濟觀點論企業風險管理與 董事監督義務*

蔡昌憲**

目 次

壹、導論：事前法律策略與事後法律策略	一、受託義務之經濟分析
貳、事前法律策略之外部他律機制：美國相關法令	二、董事監督義務概說
一、強化內控制度與法令遵循之外部法律規範	三、司法審查標準之演化
二、加強風險管理之外部法律規範	四、司法審查標準演化之相關爭議問題
三、從行為經濟學觀點檢視相關法令之規範盲點	五、從商業判斷法則之經濟分析思考董事監督義務的射程範圍
參、事後法律策略之外部他律機制：美國法上董事監督義務	六、風險治理問題之解決：公司治理機制間之互補合作
	肆、結論與啟示

* 投稿日：2012年7月9日；接受刊登日：2013年1月15日。〔責任校對：張家茹、陳榕〕。

作者衷心感謝兩位匿名審查委員與中央研究院法律學研究所出版委員會之細心指正。本文初稿曾發表於2012年6月16日由中研院法律所主辦之第四屆「法與經濟分析」學術研討會，作者非常感謝「公司法」場次主持人王文字教授、評論人林仁光教授之指教。對於簡資修教授、張永健教授及艾佳慧教授之寶貴意見，作者亦謹致謝忱。本文為作者執行國科會計畫「國際薪酬管制方向對我國企業暨金融法制之啟示：以美國2010年金融改革法及近年法院見解為中心」(NSC 101-2410-H-007-026-MY2)的部分研究成果。

** 國立清華大學科技管理學院科技法律研究所助理教授。

摘 要

金融海嘯引發企業風險管理(enterprise risk management, ERM) (下稱「風險管理」) 失靈的疑慮，令人質疑企業內部自律機制無法自我監督，從而凸顯風險治理(risk governance)之公司治理問題：何種公司治理機制可有效地達到風險管理的落實。內部自律機制既然難以正常運作，吾人轉而尋求外部他律機制以解決前開問題。詳言之，美國於金融海嘯後，試圖透過相關法令之事前法律策略來加強董事會獨立性，以解決風險治理的難題。惟囿於行為經濟學所凸顯之董事會決策過程中的固有缺陷，相關法令似仍無法促使風險管理獲得有效執行。於是，吾人再轉而思考另一種事後法律策略——美國普通法下之董事監督義務：尤其2009年的*Citigroup*案凸顯金融海嘯後，在司法審查標準上是否應將董事監督義務之射程範圍從金融海嘯前的內部控制制度及法令遵循機制層面，擴張到風險管理面向。本文循經濟觀點，贊同*Citigroup*案判決重申維護商業判斷法則的立場——該案判決未將董事監督義務擴及至風險行為之監督。本文透過探索風險治理問題的解決之道，闡明既然不論屬事前法律策略或事後法律策略之外部規範均有其侷限，公司治理問題之解決實無法僅仰賴單一公司治理機制以竟全功，最終仍需要回歸眾公司治理機制間的互補合作，來緩和代理成本問題。

關鍵詞：金融海嘯、事前法律策略、事後法律策略、行為經濟學、團體決策過程、認知偏見、受託義務、商業判斷法則、金融改革法。

Enterprise Risk Management and a Director's Duty to Monitor: An Economic Perspective

*Chang-Hsien Tsai**

Abstract

The recent financial crisis revealed enterprise risk management (“ERM”) failures while pushing us to reflect on why internal corporate governance mechanisms (“internal mechanisms”) cannot work themselves. This thus highlights a risk governance issue: which corporate governance mechanisms can effectively make ERM function? Since internal mechanisms cannot work themselves, we turn to external corporate governance mechanisms (“external mechanisms”). Specifically, in response to the financial crisis, the US aims to address the gap in risk governance through organizational reforms such as those provided in the Dodd-Frank Act that altered the structure and composition of the board of directors to further strengthen board independence. Nevertheless, such *ex ante* legal strategies as these legal reforms did not respond to shortcomings in the risk governance, namely, the influence of cognitive biases and structural dynamics on board decision-making processes. Others instead have suggested that an alternative important way of external mechanisms to limit corporate risk-taking lies in stricter enforcement by the courts of the board's duty to monitor the company's exposure to risk. In concrete terms, such *ex post* legal strategies as oversight liability underlies the plaintiffs' claim in *In re Citigroup Inc.*

* Assistant Professor, Institute of Law for Science and Technology, College of Technology Management, National Tsing Hua University.

Shareholders Derivative Litigation (2009). Some scholars propose to expand director oversight liability for ERM failures, beyond the original applications of compliance with existing legal and regulatory obligations prior to the financial crisis. This article, from an economic perspective, countenances the ruling of *Citigroup* that in order not to be contrary to all the strong policy arguments underlying the business judgment rule, director oversight liability should not be expanded for ERM failures. This article, by searching for ways to address the gap in risk governance, demonstrates that as either *ex ante* or *ex post* legal strategies have their own limitations, it's not easy to alleviate the risk of managerial misconduct by relying only on one of the corporate governance mechanisms. Therefore, we need to realize that all corporate governance mechanisms are required to be viewed as a whole, with each of them reinforcing and closing gaps left by others so as to mitigate agency problems.

KEYWORDS: the financial crisis, *ex ante* legal strategies, *ex post* legal strategies, behavioral economics, group decision-making processes, cognitive biases, fiduciary duties, business judgment rule, the Dodd-Frank Act.

壹、導論：事前法律策略與事後法律策略

美國有觀察家指出，金融海嘯(the financial crisis or meltdown)的產生，至少部分可歸咎於負責監督大型銀行的公司受託人；換言之，論者表示銀行董事對於未能防免過度風險承擔行為可謂有其過失之處¹。並且，金融海嘯之後，批評者主張，不良的企業風險管理(enterprise risk management, ERM)（下稱「風險管理」）²導致雷曼兄弟公司(Lehman Brothers)、花旗集團(Citigroup)、美國國際集團(AIG)、貝爾斯登公司(Bear Stearns)及其他金融業的經營危機³。舉例言之，美國金融危機調查委員會(Financial Crisis Inquiry Commission)在向美國國會的報告中指出，雷曼兄弟公司之破產，

1 J. ROBERT BROWN, JR. & LISA L. CASEY, *CORPORATE GOVERNANCE: CASES AND MATERIALS* 199 (2011).

2 一般而言，風險泛指面臨未來結果之一種不確定要素。Kristin N. Johnson, *Addressing Gaps in the Dodd-Frank Act: Directors' Risk Management Oversight Obligations*, 45 U. MICH. J.L. REFORM 55, 61 (2011). 企業主要面臨之風險，較重要者可大致區分為三類：作業風險(operational risk)、市場風險(market risk)、信用風險(credit risk)。Stephen M. Bainbridge, *Caremark and Enterprise Risk Management*, 34 J. CORP. L. 967, 969 (2009). 詳言之，「作業風險」係指起因於系統不良、管理疏失、控制不當、詐欺、以及人員失誤所引發之潛在損失。「市場風險」係指因金融市場價格與利率變動而生銀行持有部位價值之降低。「信用風險」係指因交易對手信用品質發生變化所致企業持有部位價值之改變。參見Michel Crouhy等著，台灣金融研訓院編譯委員會譯，*風險管理*，頁31-33（2004年）。故企業為降低違約機率及因財務危機所生之成本、管理階層基於自我利益考量、企業試圖降低資金成本以加強財務面成長的能力、以及基於累進稅制效果等前述原因，企業於是具有誘因管理其所面臨的風險。參見Michel Crouhy等著，台灣金融研訓院編譯委員會譯（註2），頁504-505。換言之，企業尚未採取風險監控政策來妥適地辨識、監督及管理與營運相關的風險暴露(risk exposure)，可能造成企業面臨鉅額的虧損。反之，企業能於市場上獲利者，常因已採納及執行有效的風險管理策略。Johnson, *supra*, at 56. 據此，企業風險管理係針對組織為達成其目標及成功執行其策略，面臨具風險性之事件或行動時所採的因應措施，藉此管理公司之風險胃納(risk appetite)及風險暴露等問題。參見吳琮璫，*審計學：實務應用與法律觀點*，4版，頁224（2009年）。See also Michelle M. Harner, *Ignoring the Writing on the Wall: The Role of Enterprise Risk Management in the Economic Crisis*, 5 J. BUS. & TECH. L. 45, 47 (2010).

3 BROWN & CASEY, *supra* note 1, at 199.

部分係起因於其包含風險管理在內之公司治理的嚴重問題；再加上該公司管理階層及交易員之薪酬發放主要是基於公司的短期獲利，使得前開風險管理問題雪上加霜⁴。無怪乎就國際規範趨勢觀之，銀行業的公司治理於金融海嘯後受到極大關注，尤其聚焦於風險管理及管理階層薪酬(executive compensation)等部分⁵。於是，美國學界不分意識型態，均一致認為金融海嘯的主要成因之一乃銀行承受過多的風險⁶。舉例言之，美國哈佛大學法學院教授Lucian A. Bebchuk等人主張，銀行業者的薪酬結構創造承擔過高風險之誘因⁷。常與Bebchuk持不同管制立場之UCLA法學院教授Stephen Bainbridge亦以為，金融海嘯凸顯出整個企業界發生近乎全面性的嚴重風險管理失靈⁸。不僅如此，美國聯邦第七巡迴上訴法院法官Richard Posner解釋風險管理失靈的背景成因而指出，在金融海嘯發生前，多年來金融業均傾向較重視創造風險之交易員（指替銀行作出放款及投資決定之人）的意見，而非減少風險的風險經理人者，蓋前者對企業獲利之貢獻較後者的貢獻易於衡量⁹。鑑此，美國學界取得共識認為，金融業應改善屬企業內部自律機制¹⁰的風險管理系統，以限制

4 *Id.* at 199-200.

5 Hwa-Jin Kim, *Toward Transatlantic Convergence in Financial Regulation* 33 (Univ. of Mich. Law & Econ., Empirical Legal Studies Center Paper No. 11-004; Univ. of Mich. Pub. Law Working Paper No. 234, 2011), available at <http://ssrn.com/abstract=1814122>.

6 See Robert T. Miller, *The Board's Duty to Monitor Risk after Citigroup*, 12 U. PA. J. BUS. L. 1153, 1153 (2010).

7 Lucian A. Bebchuk & Holger Spamann, *Regulating Bankers' Pay*, 98 GEO.L.J. 247, 247 (2010).

8 Bainbridge, *supra* note 2, at 968.

9 RICHARD A. POSNER, *A FAILURE OF CAPITALISM: THE CRISIS OF '08 AND THE DESCENT INTO DEPRESSION* 79-80 (2009).

10 本文以下將內控機制、法令遵循、風險管理歸類為企業內部自律機制；並將第「貳」部分美國相關法令及第「參」部分之董事監督義務的司法審查標準，歸類為企業外部他律機制。關於如此分類之原因，see Jingjing Yang et al., *A Review of Corporate Governance in China*, 25 ASIAN PAC. ECON. LITERATURE 15, 15 (2011) (“[R]esearchers generally place corporate governance into two categories: internal and external governance. Internal governance is primarily constituted of

未來的風險承擔¹¹。

按風險管理在概念上與內部控制制度(internal control systems) (下稱「內控制度」)及法令遵循機制(legal compliance program) (下稱「法令遵循」)皆屬企業內部自律機制，三者間具有密切關聯性；本文以為，此三者存在如後文「參、六」圖1中「非法律規範之內部監督機制」所示的關係。

詳言之，就內控制度與法令遵循之關係而論，內控制度的主要控制內容之一乃「相關法令遵循」。準此以言，內控制度需要控管公司內部運作與外部法令的一致性，藉此落實「相關法令遵循」之作業內容，故內控制度的範圍已涵蓋法令遵循¹²。其次，就法令遵循與風險管理之關係而論，法令遵循實涉及企業外部作業風險；蓋企業遵循之法令並非固定不變，而是會隨外在環境因素的改變，呈現具動態變化的遵循體制，此種法令之動態變化，即成為企業所面臨的法律風險¹³。再者，就內控制度與風險管理之關係而論，內控制度有朝向以風險為基礎之趨勢發展。易言之，內控制度及內部稽核應對公司內部風險管理控制（含風險管理單位的控制），提供更

ownership and control, characteristics and composition of the board of directors, and executive compensation; while external governance covers the production market, the takeover market, and the state regulatory system.”) (citation omitted). 亦參見易明秋，公司治政法制論，頁6（2007年）；吳琮璫（註2），頁220（「監督管理一個公司的方法包括：1. 司法監督，即司法機關依刑法、民法的監督等；2. 行政監督，即目的事業主管機關，如運輸業為交通部、金融業為金管會，依行政規章的規範及如罰則管理公司，公司法、證券法，以上二者是『他律』的機制；而3. 內部控制，則是『自律』的機制。」）。See also Yang et al., *supra*, at 24 (“Bai et al. (2004) argue that legal infrastructure is an effective external mechanism to ensure that investors receive a fair return on their investment.”).

11 See Robert T. Miller, *Oversight Liability for Risk-Management Failures at Financial Firms*, 84 S. CAL. L. REV. 47, 50-51 (2010).

12 參見王志誠，法令遵循主管制度之發展及挑戰，存款保險資訊季刊，23卷4期，頁93（2010年）（「法令遵循主管制度乃公司治理(corporate governance)中內部控制制度(internal control)之一環……。」）。

13 參見Michel Crouhy等著，台灣金融研訓院編譯委員會譯（註2），頁394。

深入的評估¹⁴。基此，風險管理的範圍實已涵蓋內控制度，二者並非替代關係，毋寧是相互補充強化的關係¹⁵。綜上所述，法令遵循乃內控制度的控制內容之一；且內控制度已朝風險管理的方向發展，故風險管理實涵蓋內控制度，而當然含括法令遵循。

然而，金融海嘯引發企業風險管理失靈(ERM failures)的疑慮，令人質疑上開包含內控制度、法令遵循與風險管理企業之內部自律機制無法自我監督，從而凸顯風險治理(risk governance)之公司治理問題；亦即，前開問題喚起吾人審視何種公司治理機制可有效地促使風險管理受到落實。循上，既然內部自律機制難以發揮功能，吾人轉而尋求法律上之外部他律機制——事前法律策略(ex ante legal strategies)與事後法律策略(ex post legal strategies)，以解決前開風險治理問題。

詳言之，來自歐美日主要國家之比較公司法權威學者經由不限於特定國家公司法的宏觀角度，試著以功能性的分析架構闡述不同法域公司法之經濟邏輯¹⁶。關於本人與代理人間代理問題之解決，其等將用來控制、最小化代理成本之法律策略，大體區分為事前法律策略及事後法律策略：前者強調在代理人行為前，相關法律策略即發揮規範效力；後者則著重於在代理人行為後，相關法律策略始對代理人之行為品質作出回應¹⁷。就事前法律策略與事後法律策略

14 參見Michel Crouhy等著，台灣金融研訓院編譯委員會譯（註2），頁96。

15 首應說明者，提倡及發布與內部控制有關之架構及相關指導原則，乃美國COSO委員會(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)之主要工作；詳細中文說明，參見王志誠（註12），頁138。COSO委員會於2001年開始研擬企業風險管理架構，並非欲取代先前所發布之內控制度架構，而係在該基礎之上，擴大內控制度所應著重之環節，並予以細緻化。王志誠（註12），頁97。亦參見陳文彬，企業內部控制評估，5版，頁146（2009年）（「……COSO ERM報告，明確地指出該風險管理包括內部控制作為一個子系統。」）。

16 REINIER KRAAKMAN ET AL., THE ANATOMY OF CORPORATE LAW: A COMPARATIVE AND FUNCTIONAL APPROACH, at vii (2d ed. 2009).

17 *Id.* at 44-45.

之例，公司法為約束董事、經理人等代理人行為，在制度設計上基本採取二種策略：其一乃制訂應作為或不作為的「事前規則」(ex ante rules)（如設立公司之最低資本額或證券主管當局訂定之上市掛牌準則）；其二乃制訂授權裁判者判斷行為是否恰當的「事後標準」(ex post standards)（如要求董事行為須基於善意(good faith)或涉及公司內部事務之受託義務）¹⁸。惟「事前規則」必須明確，同時提供讓人願意遵守之誘因；裁判者審查的「事後標準」則須考量到判決結果對法規範可能造成之影響，同時兼顧個案之公平性¹⁹。關於事前法律策略之其他例子，要求證券發行人揭露資訊則屬一種准入策略(entry strategy)，蓋此種策略要求身為代理人之發行人在與身為本人的投資人締約前（亦即法律准許其進入資本市場籌資前），須就發行人未來可能的績效表現揭露相關資訊，藉此篩除公開資本市場中具不法投機心態的發行人。由於公司之外部投資人對公開發行公司的資訊不全，故需要透過類似的事前規則強制發行人有系統地、持續地從事適當揭露，以使投資人在證券發行或買賣前獲得必要資訊²⁰。又獨立董事的設置亦屬事前法律策略之例，此乃一種受託人策略(trusteeship strategy)；蓋在將公司中重大或具利益衝突之交易的裁量權交給特定受託人——獨立董事前，透過要求董事候選人須具備獨立性之類似事前規則，使得該受託人在獲得身為本人之股東任命前，即被確認其本身之行為誘因不會不利於股東。此種策略係假設，由於獨立董事不會因不合理地圖利公司經理人或控制股東而獲得個人利益，故其等在裁量決策時會更受制於個人良心、自尊心及名譽考量²¹。

18 關於以「規則」或「標準」作為管制工具之優劣比較的權威經濟分析，see Louis Kaplow, *Rules versus Standards: An Economic Analysis*, 42 DUKE L. REV. 557 (1992).

19 See KRAAKMAN ET AL., *supra* note 16, at 39-40；王文宇，法律移植的契機與挑戰——以公司法的受託、注意與忠實義務為中心，月旦民商法雜誌，19期，頁90（2008年）。

20 KRAAKMAN ET AL., *supra* note 16, at 40.

21 *Id.* at 43-44.

惟鑑於某些規範事項相當複雜，有時法律必須採取開放性的「事後標準」，而非明確僵固的「事前規則」；例如關係人交易(self-dealing transactions)的規範，美國法院則採事後「公平原則」(a norm of fairness ex post)作為審查依據²²。類似的情形，如後文「貳、一」及「貳、二」所述，美國於金融海嘯後，試圖透過以加強董事會獨立性為主之相關法令等事前法律策略，來促進企業內部風險管理的履行。但如後文「貳、三、(三)」所論，囿於行為經濟學所凸顯之董事會決策過程中的固有缺陷，相關法令似仍無法促使風險管理獲得有效執行。於是如後文「參」的分析，吾人或應轉而思考另一事後法律策略——董事監督義務等事後標準。

關於本文的論述順序，本文第「貳」部分闡述美國立法者向來著重透過「事前法律策略」來加強董事會之獨立性，亦即以相關法令要求董事會之成員組成及組織改革作為公司治理的改革重點²³；2010年「華爾街改革與消費者保護法」(The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act，下稱「金融改革法」)，亦肯認董事獨立性將大為強化公司董事會之功效以促進內部監督機制的運作，此乃公開發行公司所生代理成本問題的解決之道²⁴。然而，自

22 參見王文字(註19)，頁90-91；KRAAKMAN ET AL., *supra* note 16, at 44.

23 See Nicola F. Sharpe, *Process over Structure: An Organizational Behavior Approach to Improving Corporate Boards*, 85 S. CAL. L. REV. 261, 274-75 (2012). 又董事會改革的方向主要可分為三類：一為成員組成改革(compositional reforms)，例如針對董事獨立性之定義及標準予以更加嚴格的規定。二為組織改革(structural reforms)，例如發展董事會下具獨立性之功能性委員會，使其等負責對執行長長的監督，或減低執行長對某些類型之重要決策的影響力；提名委員會(nominating committee)、審計委員會(audit committee)及薪酬委員會(compensation committee)皆屬之。三為改善董事誘因之改革，使其等之利益能與股東者達一致性的結果，諸如透過加強違反受託義務(fiduciary duties)時之法律責任或增加股權性質之薪酬等方式。Id. at 275.

24 See Nicola Faith Sharpe, *The Cosmetic Independence of Corporate Boards*, 34 SEATTLE U. L. REV. 1435, 1445-47 (2011). 關於管理階層之代理成本問題，中文說明可參見蔡昌憲，評我國強制設置薪酬委員會之立法政策——從經濟分析及美國金融改革法談起，中研院法學期刊，11期，頁259-260(2012年)(「許多現今公開發行公司(publicly traded corporations)主要以『經營權與所有權分離

行為經濟學(behavioral economics)觀點分析，金融改革法等美國相關法令似未完全解決董事會於決策過程中面臨之認知面及組織內的固有缺陷(cognitive and structural limitations)²⁵；故此等外部他律機制，或尚不足以有效促進風險管理之自我執行，進而全面提升金融市場的穩定性。

是以，如後文「參」的討論，美國相關法令既然不足以完全解決風險治理問題，不妨轉而考量另一項屬「事後法律策略」之外部他律機制——董事監督義務(duty to monitor)；具體而言，是否將董事監督義務之射程範圍擴張至對風險管理的監督，透過法院對董事課予較嚴格的監督義務與義務違反時的責任，來限制公司的風險承擔行為²⁶。惟本文循經濟觀點，贊同*Citigroup*案判決重申維護商業判斷法則(business judgment rule, BJR)的立場——該案判決未將董事監督義務擴及至風險行為之監督。顯然，不論屬事前法律策略或事後法律策略之外部規範均有其侷限，故而本文透過探尋風險治理問題的解決之道，說明代理成本問題之解決，需要透過企業內部自律機制、法律上外部他律機制、以及其他非屬法律規範之市場上外部他律機制等眾公司治理機制的組合，經由每一治理機制的相互協調配合，來最小化管理階層之代理成本。

(separation of ownership from control)』之方式運作，蓋公司的所有權已非由單一股東掌握，而是分散到各股東之間(dispersed ownership)。且在公司型態下，股東本人(principal)通常聘僱經理人及董事擔任代理人(agent)，代表其行使經營權，使二者存在『代理關係(agency relationship/principal-agent relationship)』。此舉雖能增進公司內部的決策效率(efficiencies in making decision)，然於股權分散結構下之代理關係中，本人通常欠缺監督代理人的誘因；且除非本人能夠精確評價及監督代理人的工作績效，並依該績效表現同步調整其薪酬，否則代理人可能會偷懶（此際有違反注意義務(duty of care)之虞）或將公司的收益據為己有（此際有違反忠實義務(duty of loyalty)之虞）。換言之，在一公司之股份所有權不集中的情形下，控制公司資產、資訊及投票機制之代理人可能成為事實上握有公司的經營權者(de facto control of the corporation)；此種聘請代理人代股東經營公司之行為，易生代理人與本人間之利益衝突(conflicts of interests)及資訊不對稱等情事，從而產生代理成本(agency cost)之問題。」。

25 詳參後文「貳、三」。

26 Miller, *supra* note 6, at 1154.

貳、事前法律策略之外部他律機制：美國相關法令

就內部自律機制而言，理論上，內控制度與法令遵循乃企業風險管理的一環，後文所述之美國相關法令似亦加以肯認。本部分以下將先說明美國就內控制度、法令遵循及風險管理之事前法律策略，再探討行為經濟學所凸顯之相關法律規範不足的問題。

一、強化內控制度與法令遵循之外部法律規範

自1972年水門案後，美國加強對企業內控制度及法令遵循之管制，並將規範對象從金融業擴及至所有公開發行公司，並制訂諸多法律規範予以落實²⁷。舉例言之，依2009年聯邦量刑準則的規定(U.S. Sentencing Guidelines Manual § 8C4.11)，法官若確定公司已建置一套「有效」的法令遵循機制來防免及偵測違法情事，其可決定減輕該公司因違法行為而處以的罰金；顯然，此準則將提供現今企業強烈誘因來建置法令遵循機制²⁸。2004年聯邦量刑準則的修正亦強調董事監督公司之法令遵循的角色：1991年之聯邦量刑準則就「有效」的法令遵循機制，雖未明確提及董事在設計及執行系爭機制之角色，惟2004之修正新增關於法令遵循的董事會監督及相關訓

27 例如：1991年聯邦量刑準則第8章、紐約證券交易所(NYSE) Rule 342及全國證券商協會(NASD) Rule 3010、以及2002年沙賓法(the Sarbanes-Oxley Act of 2002)第302條及第404條。參見黃銘傑，管窺力霸風暴中所暴露之公司治理與金融監理問題，月旦財經法雜誌，8期，16-17頁（2007年）；蕭巧玲，法令遵循制度介紹，證券暨期貨月刊，24卷9期，37-38頁（2006年）；馮震宇，企業當責與社會當責——當責不可忽略法令遵循，能力雜誌，626卷，57-65頁（2008年）；殷若瑛，修正後公開發行公司建立內部控制制度處理準則之內容，證券暨期貨月刊，24卷1期，31頁（2006年）。See also STEPHEN M. BAINBRIDGE, THE COMPLETE GUIDE TO SARBANES-OXLEY: UNDERSTANDING HOW SARBANES-OXLEY AFFECTS YOUR BUSINESS 198-222 (2007); ALAN R. PALMITER, SECURITIES REGULATION 338 (5th ed. 2011). 應予補充者，沙賓法第302條及第404條將公司與財務報導有關之內控制度法制化：前者主要規範公司編制財務報表之責任，後者主要規範管理階層對內控制度之評估。王志誠（註12），頁99。

28 Eric J. Pan, *A Board's Duty to Monitor*, 54 N.Y.L. SCH. L. REV. 717, 725 (2009).

練等規定²⁹。

應注意者，美國2002沙賓法及後續發布之證券交易市場規範，亦皆顯示美國相關法令趨勢上大幅增加董事在公司參與內控制度及法令遵循工作上之義務。舉例而言，美國證管會(Securities and Exchange Commission, SEC)依沙賓法第301條，於2003年4月發布有關規定，要求全國證券交易所及店頭市場，在一公司之審計委員會未建置關於通報其員工或他人之財務不法行為的遵循程序等情形，將不准該公司證券掛牌交易³⁰。紐約證券交易所及全國證券商協會進一步於2003年發布規則，要求上市公司須制訂及揭露企業行為及倫理守則(codes of business conduct and ethics)，該守則不僅適用於公司經理人及員工，亦適用於董事³¹；此等規定要求公司制訂可拘束董事之行為準則，不但因而要求董事須參與法令遵循之執行，亦成為大多數公司法令遵循計畫的基礎³²。紐約證券交易所亦發布另一規則³³，要求掛牌公司之審計委員會章程中，須明訂該委員會有義務協助董事會監督公司之法令遵循³⁴。

殊值說明者，隨著2000年起前數年間的公司與會計醜聞接連爆發，美國國會將許多原屬州法管制領域之公司治理議題於聯邦法中加以規範，包括公開公司中對財務會計之內控及揭露制度；其中帶來最多法令遵循成本的條文之一，乃沙賓法第404條³⁵：該條要求

29 Rebecca Walker, *Board Oversight of a Compliance Program: The Implications of Stone v. Ritter*, 1910 PLICORP 143, 146-47 (2011). 另關於聯邦量刑準則未能提供足夠誘因促使公司採行有效之法令遵循的批評，see generally Jennifer Arlen, *The Failure of the Organizational Sentencing Guidelines*, 66 U. MIAMI L. REV. 321, 325-26 (2012).

30 Walker, *supra* note 29, at 146.

31 NYSE Rule 303A.10; Nasdaq Rule 4350(n).

32 Walker, *supra* note 29, at 146.

33 NYSE Rule 303A.07(c)(i)(A).

34 Walker, *supra* note 29, at 146.

35 有關沙賓法第404條的詳細說明，詳細介紹，see Stephen M. Bainbridge, *Corporate Governance and U.S. Capital Market Competitiveness* 19-31 (UCLA Sch.

公開公司經理人須建立及維持一套關於財務報告之合適的內部控制架構及程序，且須於公司年度報告中評估此等內控機制³⁶。該法透過加諸聯邦法規上的刑事責任於公開公司，以達到敦促董事積極進行監督之目的³⁷。然而，沙賓法第404條雖立意良善，惟美國證管會低估其執行成本，造成法令遵循成本過高的現象。舉例而言，大型公司第一年的執行成本較證管會預估者高出8倍、小型公司則高出16倍³⁸。事實上，已有實證研究顯示，美國沙賓法實施一年後，美國小型公開公司被私人收購的比例顯著增加，形成一股小型公司的私有化潮(going private)的現象³⁹。蓋美國沙賓法的相關規範乃齊頭式地(one-size-fits-all)一體適用，並未區別公司大小及類型；雖對大型企業較無顯著影響，卻對小型企業造成不成比例的法令遵循成本負擔。沙賓法使小型企業成為公開公司的淨利益減少，或造成其等在法令遵循上的淨成本，故當公開化之成本上升對這些小型公司本身而言相對較劇時（相對於大型公司而言），許多不堪法令遵循成本負荷的小型公司便走向私有化一途⁴⁰。有鑑於沙賓法的法令遵循成本過高，以及其造成小型公開發行公司走向私有化的現象，故美國2010年「華爾街改革與消費者保護法」（Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act，下稱「金融改革法」）⁴¹，提

of Law, Law-Econ. Research Paper No. 10-13, 2010), available at <http://ssrn.com/abstract=1696303>. 中文簡介，參見蔡昌憲，企業自治之逆流？——擺盪於強行規定與任意規定間之累積投票制，月旦財經法雜誌，8期，頁50（2007年）。

36 See JEFFREY D. BAUMAN, CORPORATIONS LAW AND POLICY: MATERIALS AND PROBLEMS 651 (7th ed. 2010).

37 ARTHUR R. PINTO & DOUGLAS M. BRANSON, UNDERSTANDING CORPORATE LAW 236 (3d ed. 2009).

38 Stephen M. Bainbridge, *Dodd-Frank: Quack Federal Corporate Governance Round II*, 95 MINN. L. REV. 1779, 1781-82 (2011).

39 Ehud Kamar et al., *Going-Private Decisions and the Sarbanes-Oxley Act of 2002: A Cross-Country Analysis*, 25 J.L. ECON. & ORG. 107, 116-23 (2009).

40 *Id.* at 108-09, 114.

41 Pub.L. No. 111-203, 124 Stat. 1376 (2010). 本法就公司治理之規範重點，諸如：股東諮詢性投票(Say On Pay) (§ 951)；薪酬委員會之成員獨立性要求 (§ 952)；薪酬安排之強制揭露政策(Pay Disclosures) (§ 953)；擴大2002年沙賓法關於薪酬

供小型發行人豁免於沙賓法第404條(b)款中，外部獨立會計師對內控制度有效性進行證明的要求⁴²。

綜上所述，美國政府對於內控制度與法令遵循的管制密度於沙賓法達到高峰，自金融改革法後對小型公司有稍加鬆綁的趨勢。

二、加強風險管理之外部法律規範

近年來，外部規範加諸董事會監督風險管理的責任，使得美國企業風險管理受到高度重視。首先就交易市場而言，紐約證券交易所透過其上市規則⁴³，要求於該所上市之公司，須設置負有對風險評估及風險管理進行討論之職責的審計委員會⁴⁴。其次，就政府相關法令而言，公司治理一般來說被認為屬州法的傳統管制範疇，其本質乃就董事於風險管理監督之責任(accountability)與管理企業營運之權力(authority)間取得平衡⁴⁵。然而，1997年起，美國證管會發布會計報表揭露之新準則，要求上市櫃公司須公開其市場風險之量化及質化資訊，揭露市場風險暴險額以及具有市場風險敏感度之工具⁴⁶。證管會於2010年發布新規則⁴⁷，要求所有公開公司擴大對於

索回條款(Claw Back)的適用範圍(§ 954)；提供小型發行人豁免於沙賓法第404條(b)款中，外部獨立會計師對內控制度有效性進行證明的要求(§ 989G)。See Stephen M. Bainbridge, *The Corporate Governance Provisions of Dodd-Frank 2* (UCLA Sch. of Law, Law-Econ. Research Paper No. 10-14, 2010), available at <http://ssrn.com/abstract=1698898>.

42 *Id.* at 12-13.

43 N.Y. Stock Exch., Listed Company Manual, § 303A.07(b)(i)(D) (2009).

44 Miller, *supra* note 11, at 52.

45 Johnson, *supra* note 2, at 21.

46 參見Michel Crouhy等著，台灣金融研訓院編譯委員會譯（註2），頁516-517。揭露準則對於質化資訊之揭露要求包括：企業於會計年度終了描述市場風險之暴險情形、企業如何管理此風險、以及對市場風險暴險額及風險管理策略之重大變化；關於量化資訊之揭露，企業須提供量化評估與經濟暴險值間潛在不符的質化資訊，亦須提供涉及公司未來營運上直接或間接之前瞻性資訊。參見Michel Crouhy等著，台灣金融研訓院編譯委員會譯（註2），頁517-520。

47 Amendments to Rules Requiring Internet Availability of Proxy Materials, Release Nos. 33-9089, 34-61175, IC-29092, 17 C.F.R. 229, 239, 240, 274 (Feb. 28, 2010).

公司內部風險監督作業的資訊揭露（系爭資訊包括董事會在管理風險上扮演的角色）⁴⁸。

此外，美國2010年制定的金融改革法，亦是為填補公司風險治理上的缺漏之處⁴⁹。換言之，金融改革法的規範目的之一乃減少系統風險(systemic risk)；故該法有關規定透過調整董事會之組織面及成員組成，欲使董事及管理階層採取風險行為之誘因與公司長期利益更趨一致⁵⁰。例如，該法第165(h)條要求具系統重要性之公開發行金融機構(systematically important publicly traded financial companies)及公開發行的銀行控股公司(publicly traded bank-holding companies)，須設置風險管理委員會(risk committee or risk management committee，下稱「風管委員會」)⁵¹，其職責在於監督企業整體之風險管理運作⁵²；又其內須設有獨立董事，且配有至少一名曾在大型複雜之金融機構任職而具風險管理經驗的風險管理專家⁵³。

綜上，從前述美國企業關於風險管理之外部法律規範的演變，可看出企業風險管理的重要性與日俱增；同時，董事會亦被要求須於風險管理中扮演更重要的監督角色。

48 Miller, *supra* note 11, at 52.

49 Johnson, *supra* note 2, at 59.

50 *Id.* 金融改革法透過二種類型之事前法律策略來處理風險治理不足的問題：一為揭露導向的規定，另一為實質公司治理的規定（如強化董事會獨立性）。這些規定大體上均是為了處理薪酬安排與風險承擔間之連結問題，蓋前開二者若未能作妥適連結，則產生管理階層之利益衝突。倘未能有效處理此等衝突，公司內部人（含內部董事、管理階層及員工）在誘因趨使下，可能承擔過高風險，造成企業風險管理的失靈，而且亦可能導致系統風險的實現。*Id.* at 93. 關於金融改革法中，上開二種類型用以處理風險治理不足之規定的詳細說明，*see id.* at 94-100.

51 美國聯準會(the Federal Reserve)依該條授權發布新規則，要求資產高於100億美元之所有銀行控股公司及所有非銀行但受其管轄之金融機構，須設置風管委員會。GREGORY P. WILSON, *MANAGING TO THE NEW REGULATORY REALITY: DOING BUSINESS UNDER THE DODD-FRANK ACT* 104 (2011).

52 BROWN & CASEY, *supra* note 1, at 200.

53 *See* Miller, *supra* note 11, at 53; Johnson, *supra* note 2, at 106-07.

三、從行為經濟學觀點檢視相關法令之規範盲點

金融海嘯凸顯風險管理失靈的問題，無論是涉及風險意識(risk awareness)抑或是風險與薪酬間之連結，皆強調組織改革(organizational reforms)必須回應風險管理治理(risk management governance)上的盲點⁵⁴；亦即，應重視行為經濟學觀點所凸顯之團體決策過程(group decision-making processes)中認知偏見(cognitive biases)及組織內互動(structural dynamics)等內在侷限⁵⁵，並將此等組織內之固有缺陷帶來的衝擊降至最低⁵⁶。以下即從行為經濟學觀點檢視相關法令之規範盲點。

(一) 行為經濟學與公司法

在公司法學上，此種「行為」分析(behavioral approach)意指利用心理學之洞見，來處理經理人、董事、投資人及其他利害關係人間之關係、權利及責任。商學院的研究者已有一段時間透過心理學來研究組織行為(organizational behavior)及公司治理；法律學者因而

⁵⁴ 金融海嘯暴露美國大型金融機構缺乏風險意識，及其董事會未善盡監督任務及履行風險管理任務等問題；此等問題凸顯董事會就風險管理及監督之資訊蒐集及處理等決策過程仍有待檢討，且風險管理造成的重大缺失，也使得風險管理之實務運作受到高度重視。See Dirk Heremans & Katrien Bosquet, *The Future of Law and Finance after the Financial Crisis: New Perspectives on Regulation and Corporate Governance for Banks*, 2011 U. ILL. L. REV. 1551, 1558 (2011); Michael Pirson & Shann Turnbull, *Corporate Governance, Risk Management and the Financial Crisis: An Information Processing View*, 19 CORP. GOVERNANCE: AN INT'L REV. 459, 459-60 (2011). 此外，金融海嘯亦凸顯公司未體認到穩健之風險管理與妥適的薪酬決策間，二者具重要關聯性；亦即，決定管理階層薪酬之架構及程序雖為公司經理人創造誘因，卻破壞穩健的風險管理實務運作。BAUMAN, *supra* note 36, at 827.

⁵⁵ 詳見下文「貳、三、(三)」。

⁵⁶ See Johnson, *supra* note 2, at 101. 換言之，前述以金融改革法為例之相關法令並未充分解決董事會及其他團體決策機關面臨之組織中固有缺陷。*Id.* at 59. 且金融改革法為處理企業風險管理之相關規範，似不足以全面有效改善金融市場的穩定性。*Id.* at 60.

得以利用此等研究成果，分析公司法有關的議題⁵⁷。公司法的經濟分析傳統上乃採用正統財務經濟學(financial economics)在方法論上的假設——個人理性及市場效率(individual rationality and market efficiency)；此等假設常導出之結論乃批判現存法律限制之不必要或無效率，並主張解除管制(deregulation)的規範性論點來取代法律現狀⁵⁸。惟公司法或其他法律領域亦有學者提出批評，認為吾人對此等假設已過度依賴，其等轉而尋求心理學的協助來指摘理性行為人(rational actor)的模型。詳言之，關於傳統經濟分析之不足，傳統法律經濟學的觀點乃假設行為人係「理性自利」、追求「個人利益極大化」。惟行為經濟學從人類的認知及社會心理學的角度重新詮釋行為人，認為人的行為常非理性(irrationality)，且其決策常受制於偏見等問題⁵⁹。舉例而言，諾貝爾經濟學獎得主Gary Becker認為，由於人是理性且具自利心，故人會追求效用(utility)極大。但人在行為上是否真會「效用極大化」？美國經濟學家Herbert Simon不苟同「極大化」的觀點且向來主張，人的思維計算能力並不是無遠弗屆；人具有的是「有限理性」(bounded rationality)，而不是「無窮理性」。熊秉元教授進一步解釋，除了圍棋高手外，一般人恐怕最多只能猜測對手未來的兩三步。因為人是有限理性，所以人在行為上並不是追求效用極大；實際上人會根據對環境的認知以及自己有限的思維，然後作出讓自己滿意即可的選擇。與「效用極大化」的觀點相比，Herbert Simon「適可而止」(satisfying)的論點似乎更接近血肉之軀的人⁶⁰。總之，行為經濟學觀點主張，若人之行為在

57 Donald C. Langevoort, *Behavioral Approaches to Corporate Law* 1 (Georgetown Pub. Law & Legal Theory Research Paper No. 12-055; Georgetown Bus., Econ. & Regulatory Law Research Paper No. 12015, 2012), available at <http://ssrn.com/abstract=2042009>.

58 *Id.* at 2-3.

59 See PINTO & BRANSON, *supra* note 37, at 110. See also Christine Jolls et al., *A Behavioral Approach to Law and Economics*, 50 STAN. L. REV. 1471, 1476-79 (1998).

60 熊秉元，熊秉元漫步法律，頁73-74（2004年）。

預期上常不具理性或甚至僅具有有限理性，則傳統經濟分析中極端解除管制之規範性論點或不具立論基礎⁶¹。

關於傳統經濟分析與行為經濟學間愈見分歧的不同立場，2010年美國聯邦最高法院*Jones v. Harris*案（下稱「*Jones*案」）⁶²即例示此種爭論；該案涉及身為投資顧問之共同基金管理公司的受託義務(fiduciary duty)及薪酬管制議題。該案爭點在於如何對投資公司法(Investment Company Act)第36條b項進行解釋：「已登記之投資公司的投資顧問，就自該投資公司及其所屬投資人處收受服務薪酬或重大款項之行為，應被視為負有受託義務。⁶³」該法條亦授權美國證管會或該共同基金之投資人在投資顧問違反關於前開薪酬事項的受託義務時，得對該投資顧問提起訴訟⁶⁴。*Jones*案上訴到聯邦第七巡迴上訴法院時，Frank Easterbrook院長(chief judge)於其主筆之判決書中指出：縱使法院介入薪酬之制訂，並不伴隨受託義務之課予(judicial price-setting does not accompany fiduciary duties)；其亦表示，受託人必須進行完全的揭露且無欺詐情事，惟其薪酬不受法定上限拘束，蓋相較於法官和陪審團，受託人更能決定所提供之顧問服務的價值為何，而且最後若投資人不同意，其等亦會用腳和錢投票，自該共同基金外移⁶⁵。然而，同法院的Posner法官提出強烈之

61 Langevoort, *supra* note 57, at 3. 法律學者中持自由家父主義(libertarian paternalism)者，即對於行為經濟學所發現之人類認知上的侷限性加以回應，試圖保護人們免於做出錯誤的決策，而主張仍應對市場為一定的管制干預。參見蔡昌憲，美國金融消費者保護規範之展望——以消費者金融保護局之創設為中心，月旦財經法雜誌，23期，頁200-201（2010年）。關於自由家父主義與行為經濟學的進一步說明，see William A. Birdthistle, *Investment Indiscipline: A Behavioral Approach to Mutual Fund Jurisprudence*, 2010 U. ILL. L. REV. 61, 67-68 (2010).

62 *Jones v. Harris Associates*, 130 S. Ct. 1418 (2010).

63 15 U.S.C. § 80a-35(b) (2006).

64 *Id.* 亦請參見劉連煜，論美國有關證券投資信託公司與證券投資顧問事業之規範對我國之啟示，月旦法學雜誌，80期，頁161（2002年）。

65 Larry E. Ribstein, *Federal Misgovernance of Mutual Funds* 12-13 (Ill. Law & Econ. Research Paper No. LE10-018; Ill. Pub. Law Research Paper No. 10-06, 2010), available at <http://ssrn.com/abstract=1661163>.

反對意見認為：上訴法院之其他法官（即Easterbrook法官主筆之判決書）主要立基於傳統法律經濟學之觀點，來拒絕採用*Gartenberg*案⁶⁶之判斷標準；惟愈來愈多的事例指出，由於董事會欠缺有力的誘因來監督管理階層薪酬(executive compensation)之訂定，所以在大型公開發行公司中，該等薪酬通常會過高；亦即，Posner於*Jones*案的不同意見中指出「共同基金的薪酬安排問題如同發生於大型公開公司的情形，二者皆有薪酬過高的問題」⁶⁷。從而，Posner以為，這些問題顯示*Jones*案已是一個成熟的時機，吾人應對傳統法律經濟學觀點重新檢視⁶⁸。再者，Posner亦指出，吾人不能再仰賴

66 該案判決指出，違反投資公司法第36條b項而構成責任的前提，乃身為投資顧問之共同基金管理公司所收取的費用，在金額上必須是高得不成比例，使得該費用與所提供之服務間欠缺合理的連結關係，而且該費用之產生已無法說是常規交易下的產物。*Gartenberg v. Merrill Lynch Asset Management, Inc.*, 694 F.2d 923, 928 (2d Cir. 1982). 亦請參見劉連煜（註64），頁161（「關此，美國法院曾解釋此一標準為：只要報酬收費不超過雙方各自獨立之當事人『常規交易』(arms-length)（即公平協商）所得到最高費用額度之限制，即可被允許。」）。

67 Ribstein, *supra* note 65, at 2, 15. 又共同基金在美國之運作架構乃採公司型態。參見王文字，法學、經濟學與組織——兼論契約型與公司型共同基金組織（下），月旦法學雜誌，182期，頁9-10（2010年）。職此，身為投資顧問之共同基金管理公司的顧問費即如同一種向「外部」管理階層給付的薪酬。Birdthistle, *supra* note 61, at 84, 107.

68 Posner原對行為分析有所質疑。其批評所謂的「不理性」（或甚至是「有限理性」）非屬必然或普遍存在的現象，且吾人在實驗室或田野調查中觀察到關於人們不理性之證據常受限於特定的情境、事件及制度環境。換言之，在社會或經濟活動中，吾人會看到理性決策與不理想判斷的同時出現。因此，縱使傳統經濟分析可輕易地承認某些人乃不理性，這也無損於傳統經濟分析之基本立論。而且，充分競爭之市場會獎勵理性並懲罰不理性，故認知能力薄弱之人應會自市場逐漸消失，且制度環境應會有所發展以免受到偏見之干擾。再者，基於效率市場理論(efficient market theory)，只要市場套利可能於商業環境下發生，不理性行為甚至不會對市場產生短期扭曲，蓋不理性之價格波動會立即被有經驗投資人的理性行為加以利用，致使價格會回到原本理性期待之市場價值。See generally Richard A. Posner, *Rational Choice, Behavioral Economics and the Law*, 50 STAN L. REV. 1551 (1998); see also Roberta Romano, *A Comment on Information Overload, Cognitive Illusions and their Implications for Public Policy*, 59 S. CAL. L. REV. 313 (1986). 惟金融海嘯似使得Posner轉而至少某程度認同行為理論。舉例而言，針對管理階層之過高薪酬問題，Posner主張，金融海嘯之後，主要國家政府均認為對於公司薪酬安排應有一定的管制，故薪酬規範問題不在於是否進行管制，毋寧是如何規範才是最佳之管制手段。Richard A. Posner,

產品及資金市場來解決上開問題，蓋前述相同之市場誘因架構已運作於所有大型公司及類似的組織中卻發生失靈情事，共同基金之情形亦是如此⁶⁹。面對Posner和Easterbrook二位以往均支持市場觀點之當代法律經濟學大師對於Jones案卻持不同意見的情形，聯邦最高法院廢棄第七巡迴法院的判決並發回更審；最高法院判決除再次確認Gartenberg案判斷標準有所適用外，並支持透過受託義務以規範身為投資顧問之共同基金管理公司的薪酬安排⁷⁰。茲殊值注意者，Easterbrook主筆之判決意見代表著傳統法律經濟學的分析，此等分析假設一個運作良好之投資意見市場會預計到可能的投資人不理性行為，故此等分析的結論乃呼籲對共同基金產業的解除管制。Posner之不同意見所代表的行為分析，即聚焦於市場的缺陷，並考量到市場參與者常表現出之可預期非理性(predictably irrational)的行為模式，且強調市場誘因受到系統性的扭曲，故質疑傳統法律經濟

Are American CEOs Overpaid, and, If So, What If Anything Should Be Done about It?, 58 DUKE L.J. 1013, 1047 (2009) [hereinafter Posner, *CEOs Overpaid*]. Posner並修正效率市場理論觀點，轉而認同行為財務學派(behavioral-finance school)之觀點，支持公司執行長已透過種種方法以領取過高薪酬的結論。詳言之，行為財務分析發現投資人之不理性乃持續地而非偶發地出現，這些不理性行為影響整體股市活動與投資表現；並且，吾人無法仰賴市場套利來終結此等不理性行為。職是，行為財務理論證實執行長領取過高薪酬之結論。蓋此理論一方面指出，不論投資人專業與否，其可能無法以充分理性的考量來評估薪酬議題；另一方面，在許多薪酬發放係透過股票選擇權進行的情形，吾人可能難以信賴此等薪酬所立基之股價波動可用來評估股票的基本價值，亦難以據此評估執行長對這些價值之貢獻。Posner, *CEOs Overpaid*, *supra* note, at 1036-38. Posner於其2009年探討金融海嘯成因及所生經濟蕭條的專書中，不僅反思其往年對於傳統經濟分析之主張，亦開始懷疑強調解除管制之經濟理論。POSNER, *supra* note 9, at xii-xiv. 此外，美國法律學者Brian Tamanaha在“Are We Witnessing the Receding Tide of Law and Economics? (The Evolving Views of Judge Posner)”的網路文章中也指出，金融海嘯以來發生之一連串事件似乎已真正動搖Posner對於市場具有自我修正能力的信念。Brian Tamanaha, *Are We Witnessing the Receding Tide of Law and Economics? (The Evolving Views of Judge Posner)*, BALKINIZATION (Dec. 17, 2008, 10:22 AM), <http://balkin.blogspot.tw/2008/12/are-we-witnessing-receding-tide-of-law.html>.

69 Ribstein, *supra* note 65, at 15-16.

70 *Id.* at 16-17.

學所假設之理性行為人的模型；從而，Posner在此可謂含蓄地支持具謙抑性的政府干預(mild intervention)⁷¹。

最後，如後述「貳、三、(三)」的說明，行為經濟學之應用削弱傳統法律經濟學的理論根基，並對公司法之發展造成影響，例如：對團體成員造成約束的團體偏見（如下述「貳、三、(三)、(4)」的組織偏見），使成員無視於其他成員的缺點；依此觀點，將令人質疑獨立董事實際能發揮多少功能⁷²。

（二）從行為經濟學觀點看團體決策的優點

團體生產理論(team production theory)主張，公開發行公司乃為共同利得而共同合作之團體，團體成員讓渡對企業的控制權，並將其產出交予董事會，董事會成為解決團體成員爭議與治理結構之核心的中樞掌權者(a mediating hierarch)，並成為平衡股東利益與經理人誘因之守門員⁷³。如同巴賽爾銀行監督委員會(Basel Commission on Banking Supervision)的觀察，金融機構之董事會扮演異常重要的監控角色——確保銀行營運及風險管理之監督的安全與穩健；故若每家金融機構均具有效之風險管理，即可減少系統風險的威脅⁷⁴。

再者，實驗心理學家及行為經濟學家之研究發現，相對於依賴團體中的平均個人決策，集合一群人之知識、技術等要素會產生品質上較佳之決定⁷⁵。蓋以個人作為決策主體，可能易受制於個人先

⁷¹ Birdthistle, *supra* note 61, at 66-67, 106.

⁷² See *id.* at 10-12; PINTO & BRANSON, *supra* note 37, at 110. 美國學者Sharpe即認為依據法令具備表面獨立性(cosmetic independence)之董事，亦可能基於心理限制(psychological constraints)及現實限制(practical constraints)，而仍欠缺真正獨立於執行長之實質獨立性(substantive independence)。Sharpe, *supra* note 23, at 285-91.

⁷³ 有關此理論的詳細說明，see Margaret M. Blair & Lynn A. Stout, *A Team Production Theory of Corporate Law*, 85 VA. L. REV. 247, 265-76 (1999). 中文說明，參見陳錦隆，公司治理與董事高權，頁14-16（2011年）。

⁷⁴ Johnson, *supra* note 2, at 101.

⁷⁵ *Id.* at 102.

天的認知侷限(*inherent cognitive limitations*)⁷⁶；倘以團體作為決策主體，透過審慎的團體決策過程，除能克服對個人決策過程造成侷限之有限理性(*bounded rationality*)的問題外⁷⁷，且與平均個人決策的品質相較，團體決策的模式較能降低決策錯誤的機率，亦發現較多決策中可能發生的錯誤⁷⁸。據此，以董事會作為公司團體決策過程的中樞，基本上即能促使決策成員誠實並積極地參與意見交換，達成較有效率且較理性的決策結果⁷⁹。尚且，團體決策過程亦有其經濟效率的理論基礎，蓋當企業欲達成某項任務並取得最佳結果，其不必在任務一開始時即找出企業內最能幹之成員來交辦任務，反而可透過團體決策過程直接獲取該團體內最能幹成員之技能⁸⁰。綜上，以董事會作為團體決策過程的中樞有其重要性。

(三) 團體決策的缺點及相關法令的盲點

然而，以董事會作為團體決策的中樞，卻仍有其侷限存在。行為經濟學之研究顯示，以下重大的認知偏見及其他組織內互動(*structural dynamics*)等固有缺陷，均可能影響董事會中審慎的團體決策過程⁸¹：

(1) 承諾偏見(*commitment bias*)理論假設，一旦某人選擇一行

⁷⁶ *Id.* at 41.

⁷⁷ See STEPHEN M. BAINBRIDGE, *CORPORATE LAW AND ECONOMICS* 209 (2002); STEPHEN M. BAINBRIDGE, *THE NEW CORPORATE GOVERNANCE IN THEORY AND PRACTICE* 41 (2008); DANIEL F. SPULBER, *THE THEORY OF THE FIRM: MICROECONOMICS WITH ENDOGENOUS ENTREPRENEURS, FIRMS, MARKETS, AND ORGANIZATIONS* 90-91 (2009).

⁷⁸ See Johnson, *supra* note 2, at 102.

⁷⁹ *Id.*

⁸⁰ *Id.*

⁸¹ See *id.* at 103-05; Langevoort, *supra* note 57, at 10-12; Sharpe, *supra* note 23, at 286-88; Jaap W. Winter, *The Financial Crisis: Does Good Corporate Governance Matter and How to Achieve It?* 5 (DSF Policy Paper No. 14, 2011), available at <http://ssrn.com/abstract=1972057> or doi:10.2139/ssrn.1972057.

為模式，縱使事後發現的資訊指出該人應改循其他途徑，該人仍將持續採取與先前選擇一致的行為模式。此種偏見可能使得董事難以正視某證據指出，其個人先前的決策或董事會先前決策係受到誤導。

- (2) 確認偏見(confirmation bias)說明，人會傾向於忽視與已確定結論有所抵觸的資訊，且無意識地著重於對先前已明確表達之意見加以確認的資訊。此種偏見會使得個人或團體尋找並注意對最初信念或偏好進一步確認之資訊，卻漠視矛盾的意見。
- (3) 過度自信(overconfidence)指出一種過度高估團體能力或某團體領導者之能力的傾向。過度自信導致團體成員一味聽從領導人，而不對爭議問題進行認真討論，且對團體領導人之表現採過度樂觀的態度；此種偏見會破壞客觀的決策。
- (4) 組織偏見(structural bias)會妨礙董事在某事實涉及與該董事具有一定關係(relational ties and affiliations)之人時，進行客觀判斷的能力；蓋董事此際可能會對管理階層特別友善，或基於某些自我利益而討好經理人⁸²。此等關係不僅包括諸如家庭或涉及直接之金錢利益等可明確辨識出的關係，亦含其他更短期、難以看出的連結，例如曾參與共同之社團或居住同一社區、對事物有雷同想法⁸³。組織偏見使得董事會會場外之關係可能影響董事從事認真討論的能力，然而此種討論過程卻是審慎決策之所以產生效益的源

⁸² Clair A. Hill & Bret H. McDonnell, *Fiduciary Duties: The Emerging Jurisprudence*, in RESEARCH HANDBOOK ON THE ECONOMICS OF CORPORATE LAW 133, 133 (Clair A. Hill & Bret H. McDonnell eds., 2012).

⁸³ *Id.* at 149.

頭。從而，此種偏見可能妨礙團體決策過程的有效性。舉例言之，美國杜克大學法學教授James Cox及一名心理學家Harry Munsinger於1985年發表之非常具有學術影響力的經典論文，即研究應如何對於特別訴訟委員會(special litigation committee, SLC)（下稱「訴委會」）⁸⁴囿於組織偏見所作出終結代表訴訟(derivative suits)之決定進行司法審查，該文並認為組織偏見會影響訴委會中之董事獨立性⁸⁵。

- (5) 組織內互動可能因強化前開四種認知偏見而進一步惡化客觀的決策。蓋董事為避免與董事會內之主導者或大多數成員的意見相左，故未將其自身所掌握的資訊或自我判斷納入決策考量。此種董事群聚傾向(a tendency for board members to herd)破壞團體決策之效益，因而產生較無效且次佳的決定。

據此，前述團體決策過程的組織內部侷限及所造成不良決策的後果，似能用以解釋金融海嘯期間，金融機構董事會不良的團體決策過程，導致相關決策產生諸如企業風險管理失靈、破產、市場崩盤等危險性的後果⁸⁶。

⁸⁴ 董事會下另成立訴委會之目的乃用來終結代表訴訟。PINTO & BRANSON, *supra* note 37, at 488-89. 惟訴委會囿於組織偏見，故常有偏袒公司管理階層的問題。Id. at 492-95.

⁸⁵ James D. Cox & Harry L. Munsinger, *Bias in the Boardroom: Psychological Foundations and Legal Implications of Corporate Cohesion*, 48 LAW & CONTEMP. PROBS. 83, 103-04 (1985). 關於組織偏見於訴委會中的討論可謂汗牛充棟，see, e.g., Stephen M. Bainbridge, *Independent Directors and the ALI Corporate Governance Project*, 61 GEO. WASH. L. REV. 1034, 1058-59 (1993); Kenneth B. Davis, Jr., *Structural Bias, Special Litigation Committees, and the Vagaries of Director Independence*, 90 IOWA L. REV. 1305, 1306-08 (2005); Claire A. Hill & Brett H. McDonnell, *Disney, Good Faith, and Structural Bias*, 32 J. CORP. L. 833, 834, 839 (2007); Anthony Page, *Unconscious Bias and the Limits of Director Independence*, 2009 U. ILL. L. REV. 237, 245, 248, 252 (2009); Julian Velasco, *Structural Bias and the Need for Substantive Review*, 82 WASH. U. L. Q. 821, 862, 897-98 (2004).

⁸⁶ See Johnson, *supra* note 2, at 103.

實際上，金融改革法仍不變其宗地多關注強化董事會成員組成及組織的改革，仍欲主要仰賴董事會來管控經理人取得激勵性薪酬 (incentive based compensation) 之自身利益，與風險管理監督之間的利益衝突，而較少著墨增進金融機構就企業本身及系統風險之監督的改革⁸⁷。舉例言之，金融改革法第952條增修美國證交法第10C條，對於薪酬委員會成員作出相關規範，強制要求公開發行公司之薪酬委員會應具備獨立性。證管會須執行所有上市公司皆須設置薪酬委員會之要求，且薪酬委員會成員必須同時為該公司之董事並具備獨立性⁸⁸。惟此種董事會成員組成及組織的改革或屬多餘，蓋紐約證券交易所及全國證券商協會的上市規則在金融改革法立法前，均已就薪酬委員會成員之獨立性作出雷同或類似的要求⁸⁹。再者，未有證據指出全由獨立董事組成之薪酬委員會將可確保更佳的风险管理。甚且，如前所述之認知偏見限制董事行為或決策的能力，使其等之行為或決策結果無法完成理論上設想之獨立性所能達到的目的⁹⁰。此外，吾人可推知，縱使金融改革法要求特定金融機構須設置風險管理委員會，且其內須設置獨立董事，此規定能否促成較佳之風險監督，其答案可能亦難以非常樂觀。或許以上種種問題之癥結點在於，自行為經濟學觀點分析，金融改革法中對風險管理之相關管制措施，似未認真考量或反映出對董事會風險管理之監督決策過程有效性造成妨礙的固有組織缺陷——認知偏見及組織內互動⁹¹。

承上，美國相關法令等屬事前法律策略之外部他律機制，欲使內部控制、法令遵循及風險管理等內部自律機制獲得落實；惟或因如行為經濟學所凸顯之前述問題而導致使人願意遵守的誘因不足，

87 *See id.* at 100.

88 *See* LOUIS LOSS ET AL., FUNDAMENTALS OF SECURITIES REGULATION 120 (5th ed. Supp. 2011); WILSON, *supra* note 51, at 103.

89 Johnson, *supra* note 2, at 98.

90 *Id.* at 99.

91 *See id.*

從而無法完全解決董事會有效性以及進一步的風險治理問題。本文以下則考量是否另透過董事監督義務之「事後標準」的其他外部他律機制，經由給予董事避免被課予法律責任之誘因，來敦促董事會積極執行前開內部自律機制，從而解決風險治理的難題。之所以聚焦於此種州公司法的討論，乃因論者指出，德拉瓦州法院已就善意義務概念體系(*good faith jurisprudence*)⁹²加以發展，以解決組織偏見在董事會決策上造成之問題，目的是讓董事會運作不受到習慣順從於管理階層之強烈事先偏見的影響⁹³。

其次，現行風險管理實務在國際上的發展趨勢，係強調企業應進行風險管理：除要求相關風險管理政策與策略須更加透明化，並要求董事會應扮演積極監督風險管理之角色；且於風險考量下，評估公司薪酬安排的妥適性⁹⁴。此最新發展令人不禁聯想到董事監督風險管理之法律責任的射程範圍為何⁹⁵。再者，誠如Warren Buffet所言，「若一間大型金融機構之董事會未能堅持要求其執行長就風險控制負起完全的職責，則該董事會可謂有怠忽職守」；而且，「若該執行長確實未做好風險控制，該執行長及董事會應遭受嚴重的財務上後果。」Buffet所指之「財務上後果」，即引出董事監督義務與責任之議題——未適當監督及管理公司承擔之風險的董事將負起個人法律責任⁹⁶。又從前文「貳、二」可知，美國就風險管理的相關法令係透過事前法律策略（如交易市場上市規則、揭露規定或其他實質的公司治理規定），要求董事應監督風險管理，但未觸及董事是否因未落實風險監督而須負起個人法律責任之事後法律策略。職是，後文「參」將聚焦於涉及事後標準之德拉瓦州公司法判決。關

92 如後文「參、三、(三)」所述，法院將監督義務等同於善意義務。

93 See Hill & McDonnell, *supra* note 82, at 133, 142, 145, 149.

94 Michel Crouhy等著，台灣金融研訓院編譯委員會譯（註2），頁36。See also BAUMAN, *supra* note 36, at 827.

95 Johnson, *supra* note 2, at 77.

96 Miller, *supra* note 11, at 53.

此，美國學者已熱烈討論是否透過法院對董事課予更嚴格的監督義務（亦即將董事監督義務之射程範圍擴至對企業風險管理、風險暴露的監督），來限制公司的風險承擔行為；蓋如後文「參、三、（五）」的討論，2009年*Citigroup*案判決即引發此議題，乃近年來德拉瓦州公司法實務中，學者間聚訟盈庭的重大爭議之一⁹⁷。

參、事後法律策略之外部他律機制：美國法上董事監督義務

以下將透過美國德拉瓦州的重要判決⁹⁸，檢視董事監督義務在規範內涵上係如何演化，尤其觀察董事監督義務如何與內控制度、法令遵循、風險管理產生關聯性，並探討與董事監督義務之事後司法判斷標準有關的其他爭議問題。

一、受託義務之經濟分析

由於董事監督義務在概念上屬受託義務之內涵，以下先從代理成本問題出發來了解受託義務之本質。在公司裡，經理人（含高階主管(officer)及董事）乃股東之代理人，股東本可透過解任或逕自轉讓股票等方式抑制代理成本；惟單憑這些公司治理機制，通常未能有效消滅代理成本。所以，另一種法律上降低代理成本之機制——受託義務於焉產生，以要求經理人須無私地代股東行事且不可欺騙股東，同時降低資訊不對稱下所生之交易成本⁹⁹。經理人違反受託義務時將被究責之訴訟威脅，即可能遏止他們從事有違股東

⁹⁷ Miller, *supra* note 6, at 1154-56.

⁹⁸ 此等判決之初步分析，亦可參見蔡昌憲，從內控制度及風險管理之國際規範趨勢論我國的公司治理法制：兼論董事監督義務之法律移植，臺大法學論叢，41卷4期，頁1845-1849（2012年）。

⁹⁹ See Hill & McDonnell, *supra* note 82, at 135; LARRY E. RIBSTEIN & PETER V. LETSOU, BUSINESS ASSOCIATIONS 357 (4th ed. 2003).

利益之行為；亦即透過受託義務之究責，經理人將以股東利益最大化作為行事準則¹⁰⁰。

關於受託義務內容之界定，依公司法的契約論觀點¹⁰¹，為了讓公司參與人可減省締約成本，公司法提供了一組標準形式(*standard form*)或預設(*default*)條款供人採用¹⁰²。在此所指之公司法，包括立法機關制定之實定法(*statute*)以及法院的裁判；這些現成的契約條款被免費地提供給每家公司，以讓企業主能心無旁騖地經營事業。尤其，經法院判決具體化之受託義務原則(*fiduciary principle*)，填補了公司契約或實定法中之規範漏洞¹⁰³。並且，這些公司契約條款係倘當事人已預見問題且預先就系爭問題加以交涉的話，本來就會被協議出來的條款¹⁰⁴。易言之，為了訂出預設規定或填補規範漏洞，公司實定法之訂定及法院裁判之產生所依循的指導原則，乃假設性協議(*The hypothetical bargain*)的概念：當事人若就一項議約標的進行討價還價所可能實際達成之交易，即為成文法及裁判所應模擬之內容¹⁰⁵。

應注意者，由於受託義務原則係規範公司經理人之行為準則，且公司契約本身即為一個長期的繼續性契約(*long-term relational contracts*)，法院在監督及解釋此等契約上，透過受託義務原則扮演著一個不可或缺之角色。質言之，繼續性契約乃用以管控一個長期

100 See Hill & McDonnell, *supra* note 82, at 135; RIBSTEIN & LETSOU, *supra* note 99, at 360.

101 中文說明，可參見王文宇，公司法論，4版，頁21-26（2008年）。

102 See PINTO & BRANSON, *supra* note 37, at 219; Oliver Hart, *An Economist's Perspective on the Theory of the Firm*, 89 COLUM. L. REV. 1757, 1763-64 (1989); FRANK H. EASTERBROOK & DANIEL R. FISCHEL, *THE ECONOMIC STRUCTURE OF CORPORATE LAW* 14-15 (1991).

103 RIBSTEIN & LETSOU, *supra* note 99, at 358.

104 *Id.* at 359.

105 Frank H. Easterbrook & Daniel R. Fischel, *The Corporate Contract*, 89 COLUM. L. REV. 1416, 1444-45 (1989).

性的關係；在此關係中，所有偶發事件及行事標準不可能完全由當事人事先予以明定¹⁰⁶。而且，繼續性契約在締約當下必定是不完整，功能上則做為未來調整當事人間之長期權利義務關係的治理機制¹⁰⁷。在繼續性契約中，雖然法院將監督相關之事後契約修正行為，惟當事人有相當大之自由去修改任何國家所提供的標準形式契約條款¹⁰⁸。因此，繼續性契約能否合宜地調控一長期的權利義務關係，可能需視法院是否讓人信賴地扮演好監督及詮釋契約的角色。又將公司參與人間之權利義務關係看做是一個長期繼續性契約，即意味著公司法規定如同用以約束在複雜、長期之契約發展過程中可能發生的投機行為，所制定之契約法規定¹⁰⁹。換言之，在繼續性契約之長期發展過程裡，法院誠居一中心地位。而公司契約既為一長期繼續性契約，法院即以受託義務原則來調整、監管、詮釋公司參與人間之權利義務關係。

再者，當經理人合理地斷定在其提供服務之僱傭市場裡，其「一次性」(one-time)之裁量權濫用所可能招致的懲罰係值得者，此際市場機制可能已不適於處理股東與經理人間「最後回合性」(last-period)之利益分歧¹¹⁰。換言之，由於經理人可能即將退休，經理人市場之重覆賽局(repeated game)即變成單一賽局(one-shot game)；經理人既在單一賽局中不擔心「未來」會受到僱傭市場之市場機制的懲罰，故有很高的可能性會濫權地為自己利益來竊取公司資產或盜用公司機會。在市場機制失靈之際，公司法中受託義務（包括注意

106 Charles J. Goetz & Robert E. Scott, *Principles of Relational Contract*, 67 VA. L. REV. 1089, 1092 (1981).

107 OLIVER E. WILLIAMSON, *THE ECONOMIC INSTITUTIONS OF CAPITALISM* 71-72 (1985).

108 Charles J. Goetz & Robert E. Scott, *The Limits of Expanded Choice: An Analysis of the Interactions between Express and Implied Contract Terms*, 73 CAL. L. REV. 261, 266-67 (1985).

109 John C. Coffee, Jr., *The Mandatory/Enabling Balance in Corporate Law: An Essay on the Judicial Role*, 89 COLUM. L. REV. 1618, 1620 (1989).

110 RIBSTEIN & LETSOU, *supra* note 99, at 362.

義務與忠實義務)之規定即堪為「法律上」約束經理人投機行為之政府干預機制¹¹¹。

誠如公司法經濟分析之權威學者Easterbrook與Fischel主張，將公司法視為標準形式之契約條款當屬適宜。蓋受託義務規定禁止偷竊及詐欺，且明定注意義務及忠實義務之事後標準；而受託義務之規定乃大部分公司參與人若有機會選擇的話，本來就會同意的契約條款，即便這些條款僅於少數情形始會明示地於契約上約定。由於經理人會從事有違股東利益行為之情形不勝枚舉，吾人無法事前完全預見並就所有可能之情況從事締約，公司實定法中之受託義務於是僅規定用以約束經理人的抽象標準，而讓法院事後針對特定實際情事進行解釋，以填充司法審查標準之實質內容。從而，公司法規（含實定法及法院裁判）可謂替代了因就每一偶發事件(every contingency)均予詳定而將耗費高昂成本之契約條款¹¹²。總之，公司法關於受託義務之規定即為公司契約之締約當事人，在假設性協議概念下，理應挑選用來最小化代理成本之法律上不可或缺的公司治理機制。

二、董事監督義務概說

美國州法院在個案中決定受託義務(fiduciary duties)之射程範圍時，仍致力於平衡董事與管理階層在執行業務時所需的彈性(flexibility)，以及當錯誤造成時要求其等對公司之所有權人負起應盡的責任(accountable)¹¹³。換言之，無論普通法下之受託義務係如何演變，法院提出之司法審查標準，目標均朝向使董事於執行業務時能達到「權責相符」(balance a director's authority and

111 See Henry N. Butler & Larry E. Ribstein, *Opting Out of Fiduciary Duties: A Response to the Anti-Contractarians*, 65 WASH. L. REV. 1, 28-32 (1990).

112 See Frank H. Easterbrook & Daniel R. Fischel, *Corporate Control Transactions*, 91 Yale. L.J. 698, 702 (1982); Hill & McDonnell, *supra* note 82, at 135.

113 JOSEPH SHADE, BUSINESS ASSOCIATION IN A NUTSHELL 184 (3d ed. 2010).

accountability)的結果。以董事監督義務違反時之責任為例，若責任構成標準過於嚴厲，董事為規避責任可能會保守行事，故而可能選擇不從事可獲利且具可接受風險程度之商業決策¹¹⁴。惟若標準過於寬鬆，董事可能有誘因從事過高風險行為，且不願採取諸如有效之企業風險管理策略的風險監督政策¹¹⁵。自經濟觀點論之，課予董事監督責任之目的，乃藉由給予最有能力設計、執行及監督風險管理運作之人一個高度財務誘因，來改善風險管理之實際運作；美國州公司法如此之法律管制理念在於達成使董事「權責相符」之目標：董事會既有權力(authority)來管理公司之業務與事務¹¹⁶，即意味著其負有受託義務來監督公司之活動，故若董事會違反此義務，其可能被追究監督上的法律責任¹¹⁷。

有鑑於監督管理階層乃董事會原則性功能之一，董事監督義務之基本概念為：董事負有對公司之業務與政策作一般性之監督義務。惟課予董事監督義務之目的，並非期待董事有超乎常人的表現(super-human performance)；毋寧是，法院期待董事應對公司的營運內容及方式應有基本了解(rudimentary understanding)、應參與公司事務(corporate affairs)的一般性監督、應經常出席董事會、以及應定期檢視財務報表。故當董事於前述作為過程產生懷疑時，應調查致其產生懷疑之情事為何、應反對明顯違法或有疑義的行為、以及當錯誤無法被改正時應予辭職¹¹⁸。

然而，董事監督義務的範圍涉及執行業務的彈性以及董事應盡責任二者間的平衡，且法院亦未僅因董事不作為而認定其違反監督義務，故董事監督義務的射程範圍至今未有明確的絕對界線¹¹⁹。以

114 Pan, *supra* note 28, at 720.

115 Johnson, *supra* note 2, at 77-78.

116 DEL. CODE ANN. tit. 8, § 141 (2001).

117 Miller, *supra* note 11, at 53-54.

118 STEPHEN M. BAINBRIDGE, CORPORATE LAW 130 (2d ed. 2009).

119 SHADE, *supra* note 113, at 193.

下將透過美國董事監督義務於德拉瓦州之司法審查標準上的演化，探究董事監督義務隨時間推移所生監督範圍的變化；亦即，該義務於適用範圍上的演化係如何與內控制度、法令遵循、風險管理等企業內部自律機制進行互動。

三、司法審查標準之演化

(一) *Graham v. Allis Chalmers* (1963)¹²⁰

本案（下稱「*Graham*案」）乃德拉瓦州第一個判決承認董事會負有義務，來避免因公司員工違法行為而生之公司損害¹²¹。*Graham*案是一個以Allis-Chalmers公司之董事為被告所提出的代位訴訟，爭點在於該公司違反反托拉斯法是否源於董事未設立公司內控監督機制。詳言之，原告主張被告未能防免Allis-Chalmers之員工違反聯邦反托拉斯法令。原告未主張Allis-Chalmers公司董事對於該員工造成公司責任的行為已知情，原告反而主張對於該公司員工的非法行為，被告本來就應該要有所知悉¹²²。本案肯認董事受託義務包含監督義務，且從三個面向說明監督義務的基本內涵：第一，法院將監督義務置於注意義務(duty of care)的脈絡¹²³。第二，法院將監督義務定義為一消極義務(a passive duty)，蓋法院強調董事在無理由懷疑的情況下，無義務去設立並運作一個公司內部間諜系統(system of espionage)，以查明其等無理由懷疑是否存在的不當行為；此項見解因而讓董事會無誘因進行監督，且董事會獲取更多資

¹²⁰ *Graham v. Allis-Chalmers Mfg. Co.*, 188 A.2d 125 (Del. 1963).

¹²¹ Pan, *supra* note 28, at 721.

¹²² 關於該案事實之簡要中文說明，可參見Randy J. Holland著，陳春山等譯，美國公司法——德拉瓦州公司法經典案例選集，頁111（2011年）。

¹²³ Randy J. Holland著（註122），頁111。實際上，董事及管理階層違反注意義務的情況大致可分為兩種類型，一為導致錯誤發生之積極作為(action)；二為源自欠缺注意或警覺性而生的消極不作為(inaction)。基此，論者有謂，董事監督義務之違反乃前述類型二中違反注意義務的消極不作為。SHADE, *supra* note 113, at 185, 193.

訊之努力反將使自己陷於潛在的責任¹²⁴。第三，董事會僅負有阻止企業違法行為之義務；法院至此尚未思考是否將董事監督義務之範圍，延伸到防免無涉及違法行為之不良執業後果或其他有害結果等情形¹²⁵。據此，本案建立較高之董事監督義務的究責門檻¹²⁶。

(二) *In re Caremark Int'l Inc. Derivative Litig.* (1996)¹²⁷

德拉瓦州衡平法院於審理對凱馬克國際公司（Caremark International Inc.，下稱「Caremark」）董事提出之代表訴訟的和解契約時，該法院重新評估該州最高法院在*Graham*案中所作之判決意旨是否有所適用。本案起因於Caremark內某些經理人及員工可能違反聯邦「反醫療推介費用法」（Anti-Referral Payments Law）及州法中關於醫療衛生之相關規範¹²⁸。本案主要爭點在於董事應否就疏於監督下屬，違反監督公司之表現及法令遵循，而負賠償之責¹²⁹。原告主張Caremark的董事違反其等的受託義務，蓋這些董事「容任一個情況的發展與持續進行，該情況使得公司暴露於極大的法律責任之中；其等上開行為使他們違反須主動對公司營運表現進行監督的義務。」¹³⁰（下稱「Caremark案」）。

Caremark案清楚說明構成董事監督責任(oversight liability)之前

124 Pan, *supra* note 28, at 721-22.

125 *Id.* at 722.

126 See Johnson, *supra* note 2, at 81.

127 *In re Caremark Int'l Inc. Derivative Litig.*, 698 A.2d 959 (Del. Ch. 1996).

128 該法禁止醫療照顧提供者藉由支付各種形式之酬金，來誘使他人將使用老年保健醫療制度(Medicare)或醫療補助制度(Medicaid)的病患推介給這些提供者。

129 Walker, *supra* note 29, at 145. 本案試圖限縮*Graham*案的適用範圍，蓋*Graham*案判旨以為，唯在董事故意或不注意地忽視明顯可見之警戒訊號的情形，其始可能為公司的不法行為負起個人責任；惟本案法院認為，有鑑於違法情事在今日的規範環境下可能對組織造成災難性的衝擊，*Graham*案提出之標準時至今日的意義不大。*Id.* at 145-46.

130 本案原告亦陳稱董事欠缺注意的消極不作為（並非積極作出一商業決定），導致相關損失。Johnson, *supra* note 2, at 82.

提要件：(1)董事完全未實行任何通報或資訊蒐集系統或控制措施；或(2)董事確已實施如此的系統或控制措施，卻有意地不去監督或監管該等系統或措施的運作，以致於董事未能得知其應注意的風險或資訊。換言之，法院認為董事監督責任的標準，主要源自董事是否本於善意(good faith)建立並有效維持該公司內控監督系統。蓋董事負有義務本於善意，盡力確保公司應具有能進行蒐集內部資訊與報告的系統，亦即董事至少要基於善意作成決定去設置與執行內部監控通報系統，董事始已盡到注意義務之基本要求¹³¹。否則，董事會在作成監督與管理之決策就不能本於合理且及時的資訊；若因此造成公司損害，董事即應負責。由此可知，董事監督義務違反之責任成立，係基於董事會持續性或系統性怠於監督，且該持續性行為欠缺善意，始有構成違反監督義務之可能。此外，法院說明原告欲主張因董事違反其注意義務¹³²，而課予董事未盡董事監督義務之責任者，則原告須先證明以下二種主觀要件之一該當：(1)董事對員工之違法行為已知悉(knew)；(2)應知而未知(should have known)該違法行為。原告除須證明前開二種主觀要件之一外，另須證明：(3)董事未盡善意之努力(took no steps in a good faith effort)以防止該違法行為；(4)董事上述之消極不作為與公司之損害間有相當因果關係¹³³。

職此，德拉瓦州衡平法院採取「警示紅旗」(red flag test)的見解¹³⁴，認為董事注意義務包含建立並有效維持一內控制度；若公司因員工之違法行為而受到行政機關裁罰或對第三人須負賠償責任，

131 林國彬，董事忠誠義務與司法審查標準之研究——以美國德拉瓦州公司法為主要範圍，政大法學評論，100期，頁150（2007年）。

132 Johnson, *supra* note 2, at 83 (“[T]he Caremark decision . . . also seemed to revive *duty of care* claims that the Delaware state legislature intended to eliminate by statute.”) (emphasis added).

133 *Caremark*, 698 A.2d at 971；參見林國彬（註131），頁151。

134 進一步說明，請參見後文「參、三、(三)」。

則於股東訴訟要求董事賠償公司因此所受之損害時，董事必須舉證證明公司已建立並有效維持其內部監控通報系統。若公司已建立該系統者，則舉證責任轉移至原告，原告須證明前述四點關於有違反注意義務之虞的要件存在。若原告未能證明，則董事因已盡其注意義務，而對公司損害無須負責。惟若董事未能證明該內控系統存在，或該存在之系統並無實質功能，則違反董事注意義務，即應對公司負損害賠償之責¹³⁵。

(三) Stone v. Ritter (2006)¹³⁶

本案起因於美南公司(AmSouth Bancorporation)於2000年有「至少一位」員工懷疑執業律師Louis D. Hamric與任職於紐約互惠人壽保險公司(Mutual of New York)的註冊投資顧問Victor G. Nance二人，涉及一項可疑非法活動，惟該公司卻未能及時向主管機關申報可疑活動報告(Suspicious Activity Reports, SARs)。在2004年，美南公司及美南銀行(AmSouth Bank)¹³⁷支付美金4千萬的罰款與1千萬的行政罰鍰，來解決政府管制機關之各項調查；這些調查主要是關於美南銀行行員未能依據聯邦「銀行保密法」(Bank Secrecy Act, BSA)及各種「反洗錢」(anti-money-laundering, AML)法令，申報客戶的「可疑活動報告」。然而，美南公司的董事未被處以任何罰款或行政罰鍰，他們亦未遭到其他政府管制機關的查處(regulatory action)。

原告主張美南公司之董事已違反其等的監督義務；亦即，董事完全未能本於善意建置種種措施及程序來確保公司遵守銀行保密法與反洗錢法令下的義務，這使得董事非常可能被追究責任(face a “substantial likelihood of liability”)（下稱「Stone案」）。德拉瓦州衡

¹³⁵ 參見林國彬（註131），頁151。

¹³⁶ Stone v. Ritter, 911 A.2d 362 (Del. 2006).

¹³⁷ 美南銀行(AmSouth Bank)為美南公司全權持股之子公司，該銀行當時在美國東南部之六州有大約600家從事商業銀行業務的分行，並僱用超過11,600名的員工。

平法院發現，原告未主張有「警示紅旗」的存在——「警示紅旗」意指：「相關事實顯示出：董事會曾意識到美南公司的內控制度已有不當；這些不當的情形將導致非法行為的出現；董事會卻仍選擇對被聲稱其已知存在的問題置若罔聞。」

此外，德拉瓦州最高法院認為原告的主張是以後見之明，試圖將壞結果的發生與惡意(bad faith)的存在劃上等號；此主張帶有一個缺陷，亦即其等未能認知到，即使董事能善意地執行監督任務，不一定永遠讓員工不會違反刑事法規，也不一定總是使公司不會身陷嚴重的財務責任，亦不一定必能避免前開二種情形不發生¹³⁸。在缺乏警示紅旗的情況，就衡量監督層面是否本於善意而論，實不可在員工從事某些行為導致非預期之不良結果後，即進行事後猜測(second-guessing)；毋寧是，應視董事是否有「確保一個合理之資訊蒐集及通報系統的存在」等行為而定。職是，法院明確指出怠於監督所生之賠償責任判斷標準：(1)董事完全沒有建置任何報告或資訊系統或控制制度；(2)雖已建置該等系統或控制制度，卻有意識地怠於(conscious disregard)監督或控制其運作，致董事無法了解應注意的風險或問題¹³⁹。

應注意者，德拉瓦州最高法院於本案表示，*Caremark*案對於所謂「監督」責任(“oversight” liability)的標準，主要源自董事未能本於善意行事的觀念。前開標準與該法院在*Disney*案¹⁴⁰判決中所認可之惡意(bad faith)的定義相互一致；在*Disney*案中，該法院認為，未本於善意行事之行為態樣，與違反受託人之注意義務的行為（亦即重大過失）之間，有著質的不同，且又以前者的可責性較高。在

¹³⁸ 由此可見，本案法院承認董事監督及法令遵循必有其功能上的極限；亦即，無論法令遵循是如何積極有效地執行，其仍有本質上的侷限性。從而，論者有謂，此點將有助於公司於違法情事發生後，主張其已基於善意執行法令遵循，利用此種抗辯來免除責任。Walker, *supra* note 29, at 148.

¹³⁹ Stone, 911 A.2d at 367.

¹⁴⁰ *In re Walt Disney Co. Derivative Litig.*, 906 A.2d 27 (Del. 2006).

*Disney*案中，該法院識別出數種行為之例，足堪認定是未本於善意行事的行為態樣；其中之一，乃受託人在作為義務下有意地不作為，此充分說明其有意識地忽視其義務的要求(a conscious disregard for his duties)¹⁴¹。該法院進一步指出，前開有意之不作為即是一種未本於善意行事的行為態樣；此乃*Caremark*案中法院判決提到之董事監督義務的必要條件，亦即「董事會持續地或經常地未履行其監督義務的情形（諸如完全未能試著去確保一個合理之資訊蒐集及通報系統的存在）」¹⁴²。

（四）AIG v. Greenberg (2009)¹⁴³

本案乃美國國際集團（American International Group，下稱「AIG」）股東作為原告，其對該集團的前任董事兼管理階層、以及負責AIG財務報告之會計公司，所提起之代表訴訟。原告主張AIG前任董事怠於維持公司內控制度之有效運作，致生管理階層之操縱市場(big-rigging)、詐欺及不當的會計手段，使得公司受到嚴重損害；此乃違反忠實義務(duty of loyalty)下的「董事監督義務」(fail to monitor)（下稱「AIG案」）¹⁴⁴。本案法院判斷監督義務之標準在於，董事從事系爭不法行為時，是否知悉該公司內控制度及法令遵

141 善意之欠缺（亦即惡意）須參照聯邦證券法特定規定中之scienter的要件來理解。Miller, *supra* note 6, at 1157. 賴英照教授指出，以美國1934年證券交易法「§ 10(b)或Rule 10b-5起訴者，須被告有故意或間接故意(scienter)之行為」。賴英照，股市遊戲規則——最新證券交易法解析，2版，頁787-788（2011年）。由是可知，監督責任的構成要件之一乃間接故意或未必故意，從而原告負有舉證責任，須證明董事就義務違反實已知悉(knew)。Miller, *supra* note 6, at 1157. 所以，惡意即指具間接或未必故意。In re Citigroup S'holder Derivative Litig., 964 A.2d 106, 125 (Del. Ch. 2009) (“‘bad faith’ conduct, a plaintiff must also plead particularized facts that demonstrate that the directors acted with scienter, i.e., that they had ‘actual or constructive knowledge’ that their conduct was legally improper.”).

142 Johnson, *supra* note 2, at 83.

143 AIG v. Greenberg, 965 A.2d 763 (Del. Ch. 2009).

144 有關AIG內部經營問題之詳細介紹，see generally RODDY BOYD, FATAL RISK: A CAUTIONARY TALE OF AIG'S CORPORATE SUICIDE (2011).

循乃不適當，並容任不當之法令遵循機制存續；以及知悉有不法行為，卻未能讓AIG董事會全體成員注意到該不法行為¹⁴⁵。換言之，若董事對於監督公司內控制度及法令遵循的欠缺，應有所作為來改善卻故意不作為，導致因未盡監督義務而產生諸多不法情事，則該董事應為其違反忠實義務下之監督義務的行為負賠償責任。

關於AIG經理人進行之一系列的詐欺陰謀，本案原告雖未能提供直接證據證明被告對充斥於AIG的諸多詐欺交易，有所知悉¹⁴⁶；惟本案法院將被告董事視為犯罪組織的一員¹⁴⁷，認為此等詐欺行為牽涉層面甚廣，由法院來看被告顯不可能毫不知情¹⁴⁸。進一步而言，本案二被告既身兼公司的管理階層及董事¹⁴⁹，其等故意(knowingly)容認不適當的內控制度存續，且故意未監督其等下屬的法令遵循情形¹⁵⁰。法院於是推論被告因其在公司內地位而得以知悉，故其等不可能對不法交易之進行毫無所悉¹⁵¹。其次，二名被告於企業中皆直接控制涉及詐欺及違法活動之公司內各部門¹⁵²。準此，法院依據二名被告於公司內的角色及控制力，推論本案被告董事應有所知悉；然而，法院依此推論來執行監督義務之情形可說是僅在AIG案如此不尋常的事實背景下才可能發生，尤其在一般不行使此種控制力之外部董事的情形，前開推論誠不可能成立¹⁵³。綜上，被告董事違反

145 *AIG*, 965 A.2d at 777-78.

146 *Id.* at 782 (“Although the Stockholder Plaintiffs provide detailed allegations about the illegal transactions and schemes that proliferated at AIG, they are not able to tie all of the defendants directly with specific facts to all of the schemes.”).

147 *Id.* at 798-99.

148 *Id.* at 782 (“Even the transactions that cannot be tied to specific defendants support the inference that, given the pervasiveness of the fraud, Greenberg and his Inner Circle knew that AIG was engaging in illegal conduct.”).

149 *Id.* at 774.

150 *Id.* at 799.

151 *Id.* at 796-99.

152 *Id.* at 797.

153 *Pan, supra* note 28, at 736.

忠實義務下有效維持內控制度及法令遵循的監督義務。

(五) *In re Citigroup S'holder Derivative Litig.* (2009)¹⁵⁴

*Stone*案及*AIG*案仍未解決董事監督義務之監督範圍，是否包含諸如財務、市場或信用之風險管理等問題。惟如本案所述，金融機構於金融海嘯期間所經歷的重大危機，提供法院一個機會進一步澄清董事監督義務之射程範圍¹⁵⁵。詳言之，於次貸危機及金融海嘯的衝擊下，花旗集團(Citigroup)面臨三種企業風險——作業風險、市場風險及信用風險，導致企業蒙受嚴重虧損¹⁵⁶。花旗集團於2008年受到金融海嘯及信用市場危機的衝擊後，宣布將尋找具備「財務及投資」專業的新董事。此舉暗示2008年7月當時該行的十名獨立董事，普遍不具備足夠的財務專業，無法全盤了解公司的財務及投資狀況，以致於無法作成正確的商業決定，從而造成公司的嚴重虧損¹⁵⁷。在此背景下，本案原告主張被告董事會未適當監控、管理公司之風險暴露¹⁵⁸，並忽視對愈加惡化之次貸市場(subprime mortgage market)提出警戒訊號的警示紅旗，故被告董事會違反其監督義務(下稱「*Citigroup*案」)¹⁵⁹。惟法院認為原告所陳稱之警戒訊號，無法證明被告董事有意識地怠於(conscious disregard)履行其監督義務或具惡意的行為；此等證據充其量證明他們的決策屬不良的商業決定(a bad business decision)，且原告所提出的警示紅旗亦僅反映次級

154 *In re Citigroup S'holder Derivative Litig.*, 964 A.2d 106 (Del. Ch. 2009).

155 Johnson, *supra* note 2, at 86-87.

156 Bainbridge, *supra* note 2, at 978. 關於作業風險、市場風險及信用風險的定義，可參見前註2的說明。

157 See Eric Dash, *Dean of Harvard Business School May Join Citigroup's Board*, N.Y. TIMES (July 9, 2008), <http://www.nytimes.com/2008/07/09/business/09citi.html>; Nicola Faith Sharpe, *Rethinking Board Function in the Wake of the 2008 Financial Crisis*, 5 J. BUS. & TECH. L. 99, 109 (2010).

158 *Citigroup*, 964 A.2d at 123 (“[P]laintiffs' *Caremark* claims are based on defendants' alleged failure to properly monitor Citigroup's *business risk*, specifically its exposure to the subprime mortgage market.”).

159 Pan, *supra* note 28, at 738.

房貸市場及整體經濟情勢的每況愈下¹⁶⁰。

應注意者，本案原告以舉證難度極高的*Caremark*請求(*Caremark Claims*)¹⁶¹，要求董事應對其未履行監督商業風險(*business risk*)的義務，負個人責任(*personal director liability*)¹⁶²。詳言之，原告必須突破以下三項障礙，始盡此相當高之舉證責任，來主張被告董事因未監控公司之商業風險程度而須負個人責任：¹⁶³(1)被告所受商業判斷法則之推定上保護、(2)德拉瓦州公司法第102條b項第7款之董事注意義務違反責任的免責條款¹⁶⁴、以及(3)*Caremark*請求所要求之高舉證責任¹⁶⁵。

¹⁶⁰ *Citigroup*, 964 A.2d at 128.

¹⁶¹ 典型的*Caremark*請求係指，原告主張因被告未適當監督或監控員工的不法行為，而須對公司損害負賠償責任。*Id.* at 123. *See also* BROWN & CASEY, *supra* note 1, at 180 (“Relying on Chancellor Allen’s dicta, courts came to recognize so-called ‘Care-mark claim’— causes of action alleging that the board of directors’ ‘utter failure’ or ‘systematic failure’ to monitor legal compliance caused injury to the corporation.”).

¹⁶² *Citigroup*, 964 A.2d at 125 (“[A]s former-Chancellor Allen noted in *Caremark*, director liability based on the duty of oversight ‘is possibly the most difficult theory in corporation law upon which a plaintiff might hope to win a judgment.’”).

¹⁶³ *Id.* at 125. 進一步說明，*see* Anne Tucker Nees, *Who’s the Boss? Unmasking Oversight Liability within the Corporate Power Puzzle*, 35 DEL. J. CORP. L. 199, 206 (2010).

¹⁶⁴ 德拉瓦州公司法第102條b項第7款之立法目的，乃允許股東在公司章程中明定，若董事違反注意義務時，可免除其個人之財產上損害賠償責任，蓋股東授權董事隨時履行其受託人責任。但上開免責範圍並不包括違反忠實義務，及未本於善意行事的情形。此項立法於1986年通過後，德拉瓦州法院均一致認為：在符合第102條b項第7款之情形，公司採納上開立法，容許董事於違反注意義務時，可免負財產上之損害賠償責任的章程規定係屬有效。Randy J. Holland著，陳春山等譯（註122），頁133。See also Johnson, *supra* note 2, at 83; Miller, *supra* note 6, at 1161-62; BROWN & CASEY, *supra* note 1, at 187.

¹⁶⁵ 此特別是針對主觀要件而言。蓋原告雖主張被告董事未作出善意的努力來遵守已建立之監督程序，法院認為原告終究須證明被告董事惡意行為的存在，以證實董事監督責任的成立；亦即提出具體事證證明被告有意識地怠於履行其義務。*Citigroup*, 964 A.2d at 127-28. 事實上，原告亦未能提出具體事證證明被告董事「知悉」(*knew*)其等未適當監督公司的風險；也就是說，原告未能提出事實證明間接故意(*scienter*)此一主觀要件的存在，故原告主張未合於依*Caremark*案及*Stone*案下的請求。Miller, *supra* note 6, at 1160.

綜合而言，法院基於以下兩個原因駁回原告的請求：(1)董事會不應因未監督商業風險而被課予責任。法院認為，德拉瓦州普通法所指之董事監督義務，僅要求董事會應建置監督方案，以監督詐欺或不法；倘若將董事監督義務的監督範圍擴及商業風險，法院將會侵入董事會之商業判斷的範疇¹⁶⁶。(2)董事會作成一項商業決定，縱該決定事後證明非屬明智，亦不能據此不明智之商業決定，課予董事責任。蓋若擴大董事監督責任範疇，要求董事為不良的商業結果負責，法院會被迫對董事會商業判斷從事不適當的事後猜測(second guessing)；此種作法將與商業判斷法則之目的有所悖離¹⁶⁷。進一步而論，倘若法院涉入評價董事會對商業風險之監督是否成功，則代表法院事後評價商業決策的實質面；本案法院指出，此種評價將冒著「事後諸葛偏見」(hindsight bias)的危險，此危險意指知悉事情最後發展結果之人，傾向於誇大其相信該結果本可被預見的程度¹⁶⁸。

四、司法審查標準演化之相關爭議問題

(一) 終結受託義務三分說並確立受託義務二分說：以 *Stone* 案為分水嶺

美國判例法之受託義務的內涵，於法院實務上曾有爭議，主要見解有二：一為二分說，一為三分說。前說認為受託義務僅由忠實義務與注意義務所構成，後說則強調受託義務係由忠實義務、注意義務與善意義務(duty of good faith)三者所構成¹⁶⁹。殊值注意者，二分說與三分說最重要差異在於，善意義務是否能成為獨立的責任構成原因之一？若否，則其應置於忠實義務抑或是注意義務之下？

¹⁶⁶ Pan, *supra* note 28, at 738.

¹⁶⁷ *Id.* at 738-39.

¹⁶⁸ *Id.* at 739.

¹⁶⁹ 邵慶平，董事受託義務內涵與類型的再思考：從監督義務與守法義務的比較研究出發，臺北大學法學論叢，66期，頁30-31（2007年）。

美國德拉瓦州最高法院於1993年*Cede & Co. v. Technicolor, Inc.*案¹⁷⁰，首次宣告公司董事之受託義務除注意義務及忠實義務外，尚包含第三種的善意義務；基此，受託義務從傳統二分說走向三分說¹⁷¹。嗣後，該法院雖於*Disney*案中進一步說明善意義務之意義為何，卻未說明善意義務應置於受託義務中的忠實義務或注意義務之下。故善意義務應置於受託義務中何一脈絡下的不確定性，促使德拉瓦州最高法院利用*Stone*案審查*Caremark*請求時作出回應，將監督義務等同於善意義務，並將善意義務歸於忠實義務下之一環¹⁷²。

可見，創造三分說既未解決董事受託義務於司法審查上的困難，亦混淆法院及當事人對受託義務之適用及解釋¹⁷³。故*Stone*案否定善意義務作為受託義務下獨立義務的一種類型，肯認善意義務乃忠實義務之重要內涵——也就是「忠實的心理狀況」(a loyal state of mind)；然而，此結論並非否定善意義務於公司法的重要性，而是藉此強化並執行善意義務於忠實義務此種最重要之受託義務下所扮演的關鍵角色¹⁷⁴。故*Stone*案後，監督義務之違反係指面對已知之作為義務卻故意不作為的一種惡意行為，此種善意之欠缺即屬忠實義務之違反，從而德拉瓦州公司法第102條b項第7款之董事注意義務違反責任的免責條款於此無適用餘地¹⁷⁵。2009年德拉瓦州最高

170 *Cede & Co. v. Technicolor, Inc.*, 634 A.2d 345, 361 (Del. 1993).

171 Leo E. Strine, Jr. et al., *Loyalty's Core Demand: The Defining Role of Good Faith in Corporation Law*, 98 GEO. L.J. 629, 631 (2010). See also Robert B. Thompson, *The Short but Interesting Life of Good Faith as an Independent Liability Rule*, 55 N.Y.L. SCH. L. REV. 543, 544 (2010).

172 Pan, *supra* note 28, at 727. 應注意者，在*Stone*案，德拉瓦州最高法院澄清善意義務非屬受託義務的獨立類型，僅是忠實義務的要件之一；惟*Caremark*案中，法院則認為善意義務與注意義務有關。BROWN & CASEY, *supra* note 1, at 187.

173 Strine et al., *supra* note 171, at 634.

174 *Id.* at 696.

175 See PINTO & BRANSON, *supra* note 37, at 231; Johnson, *supra* note 2, at 86; Walker, *supra* note 29, at 147 (“[U]nlike claims that directors have violated their duty of care, corporations cannot limit or eliminate directors’ liability for violating their

法院在 *Lyondell Chemical Co. v. Ryan*¹⁷⁶ 案，正式終結善意義務作為受託義務之獨立義務類型的一種¹⁷⁷。

至此，再次確立德拉瓦州最高法院採受託義務二分說，僅有注意義務及忠實義務兩大類型；而且忠實義務之適用並不僅限於一般所了解的利益衝突情況，本亦包括欠缺善意的行為¹⁷⁸。惟美國學者 Bainbridge 等人批評，*Stone* 案造成善意義務與監督義務適用上的混淆；其等進一步指出 *Stone* 案將善意義務與監督義務整合，可能造成二者適用紊亂的結果，故德拉瓦州法院未來仍須釐清此種適用上的不確定性¹⁷⁹。無論如何，*Stone* 案對於 *Caremark* 案法院要求董事有義務積極採取一些法令遵循措施的意見加以確認，*Caremark* 案的此項意見成為審查董事因違反其監督義務而須負責之必要條件¹⁸⁰。

duty of loyalty.”). 如前註123所述，有論者指出，監督義務之違反本亦可主張成注意義務之違反；然而，前開免責條款之廣為使用即意味著，實際上若要成功地作出董事監督義務違反的主張，則必須主張成忠實義務之違反。Nees, *supra* note 163, at 204. 惟 *Citigroup* 案的法院指出，(1)就無涉利害關係之董事所為決定在公司章程採用前開免責條款下，是否有構成注意義務違反責任的審查標準，與(2)監督義務之責任構成的審查標準相較，二者間有類似性。蓋不論在何一種情形，原告可證明若被告董事之作為或不作為構成惡意，董事即應負責。舉例言之，如前者(1)因積極作為而違反注意義務的一般情形，原告可舉出事實證明董事有意地忽視(*consciously disregarded*)其就公司業務及風險應受合理告知的義務；如後者(2)因消極不作為而違反監督義務的情形，原告可舉出事實證明董事有意地忽視其監督及監控公司業務之義務。故無論在上述何種情形，原告均可證明被告有惡意行為的存在。*Citigroup*, 964 A.2d at 125. 準此，由於德拉瓦州公司法第102條b項第7款的免責範圍不包括未本於善意（亦即惡意）行事的情形，吾人以為不論在(1)或(2)任一情形，原告若能證明惡意行為的存在，被告董事即不能據以免責。

176 *Lyondell Chemical Co. v. Ryan*, 970 A.2d 235 (Del. 2009).

177 Thompson, *supra* note 171, at 544.

178 2 JAMES D. COX & THOMAS LEE HAZEN, *THE LAW OF CORPORATIONS* 153 (3d ed. 2010).

179 Stephen M. Bainbridge, Star Lopez & Benjamin Oklan, *The Convergence of Good Faith and Oversight*, 55 UCLA L. REV. 559, 605 (2008) (“The convergence of good faith and oversight thus is one of those unfortunate marriages that leaves both sides worse off.”).

180 *Id.* at 559.

(二) 董事監督義務與內控制度及法令遵循間的連結：*Caremark*案、*Stone* 案

承上，*Caremark*案前，德拉瓦州法院雖於*Graham*案中表示不期待董事會於日常公司管理中有過多的涉入，故此時期所建立之以執行長為中心的公司治理模式幾乎不課予董事會監督公司內部經理人及員工之義務；亦即，德拉瓦州最高法院對於董事會是否應努力確保公司內部資訊通報系統（此等資訊含法令遵循的實況），未有明確說明¹⁸¹。直到*Caremark*案，始進一步填充董事監督義務的實質內容，建立較明確的審查標準¹⁸²。*Caremark*案指出建立並評估內控制度的合適性及資訊通報系統(information-reporting systems)，乃董事會履行其監督義務的重要內涵¹⁸³；且該審查標準亦於其他有關監督義務的案件中被其他州法院加以採納¹⁸⁴。綜上所述，*Caremark*案說明，建立並有效維持資訊通報系統，以避免公司內部經理人及員工產生不法行為，乃董事監督義務的本質內涵。實際上，*Caremark*案所指之資訊通報系統似可對應於現今企業採行之含法令遵循在內的內控制度；蓋該案法院明確提到以聯邦量刑準則作為一項考量因素，來決定董事會監督公司法令遵循機制的合適水平。該案法院指出，該準則提供公司有力的誘因來建置法令遵循機制，且任何欲本於善意履行組織治理任務的理性之人，必定會考慮利用該準則提供予公司減刑之好處¹⁸⁵。

嗣後，*Stone*案雖續採*Caremark*案之董事監督義務內涵作為審查標準，惟*Stone*案限縮董事監督義務的適用範圍¹⁸⁶。法院主要透

181 See Pan, *supra* note 28, at 724, 726.

182 *Id.* at 726. See also Johnson, *supra* note 2, at 25 (“*Caremark* introduces Delaware’s duty to monitor doctrine.”).

183 See Pan, *supra* note 28, at 726.

184 SHADE, *supra* note 113, at 198.

185 See Walker, *supra* note 29, at 146; Pan, *supra* note 28, at 725.

186 Pan, *supra* note 28, at 726.

過三個層面，限縮董事監督義務之適用範圍：(1)法院將董事監督義務與善意義務畫上等號；(2)法院將善意義務置於忠實義務之下；(3)法院將知悉(knew)、間接故意(scienter)，解釋成一種認定惡意(bad faith)、有意識地怠於(conscious disregarded)監督的要件¹⁸⁷。儘管將監督義務重新分類並置於忠實義務之下，得將監督失靈情形排除於德拉瓦州公司法第102條b項第7款章程免責條款的適用範圍之外，惟此舉卻同時造成原告證明被告董事違反監督義務的舉證責任難度大幅提高¹⁸⁸。

(三) 釐清董事監督義務與法令遵循及風險管理的關係：

Caremark 案、*AIG* 案及 *Citigroup* 案

*Caremark*案顯示設置內涵為資訊通報系統之內控制度，與建置法令遵循機制之間有重要關聯性。該判決中揭示董事有義務確保其公司具有法令遵循機制，且有義務監督公司調查有疑義的活動¹⁸⁹。審理*Caremark*案的德拉瓦州衡平法院William T. Allen前院長指出，董事會具有本於善意確保公司遵循相關法令及管制準則的義務¹⁹⁰。實際上，現已轉任美國紐約大學講座教授的Allen縱使於本案面對擴張董事之監督角色的難題，其仍能一方面顧及在避免法院過於介入商業決定的前提下，另一方面利用受託義務的究責引導企業對於法令遵循更加重視。換言之，*Caremark*案代表著一項觀點的勝利：德拉瓦州法官不應審查董事決定之合理性（吾人以為此點再度確認商業判斷法則之基本理念）；反而是，無涉利益衝突之董事僅於其等基於主觀惡意行事之情形始應負責¹⁹¹。惟論者批評，此觀點基於以

187 *Id.* at 727.

188 *Id.*

189 Jennifer Arlen, *The Story of Allis-Chalmers, Caremark, and Stone: Directors' Evolving Duty to Monitor*, in *CORPORATE LAW STORIES* 323, 344 (J. Mark Ramseyer ed., 2009).

190 Johnson, *supra* note 2, at 82.

191 Arlen, *supra* note 189, at 344.

下三個原因，難以導出董事積極從事法令遵循監督的結果：(1)此監督義務內涵不夠具體，而無法促使不願挑戰管理階層之董事對調查活動進行積極監督；(2)惡意的歸責標準(the bad faith liability standard)使董事易於規避，以致無法提供實質嚇阻效果；(3)此義務無法透過道德勸說(moral suasion)，誘使董事從事積極且有效的監督行為¹⁹²。

基此，論者以為若無其他配套措施（例如增加董事獨立性、專業性以及管理階層支持法令遵循機制），可能無法達到*Caremark*案所期待董事積極履行其監督法令遵循的義務¹⁹³。故為達成董事監督的有效性，可透過下述三種配套措施加強董事監督義務之履行：(1)增加外部董事的職權(authority)、獨立性及專業性；(2)德拉瓦州法院須清楚表明，外部董事應就公司內部分析某行為是否違法乙事進行獨立監督；(3)聯邦政府應清楚界定合法及非法行為(clarify the line between legal and illegal conduct)，以利外部董事有效挑戰其認為非法之管理階層所作的決定¹⁹⁴。從另一角度觀之，如前文「壹」導論中已提及，董事會改革的三個基本要素可分為：組織改革(structural reform)、成員組成改革(compositional reform)及監督之決策過程改革(process reform)。實際上，前述三項董事會改革之基本元素具相互關聯性，難以僅由單一或前二項要素之強化，即達到良好的改革成效¹⁹⁵。綜上，吾人應同步協調強化組織層面、成員組成及監督決策過程等董事會改革三要素，以提升董事會監督的實質有效性¹⁹⁶。

再者，*Citigroup*案判決某程度可謂為*Caremark*案及*Stone*案之審

192 *Id.*

193 *Id.*

194 *Id.* at 346.

195 See Sharpe, *supra* note 23, at 291.

196 *Id.* at 291-92.

查標準的綜合體現。尤其，法官亦檢驗董事主觀面是否有意識地怠於(consciously disregarded)履行其監督義務。雖然*Citigroup*案原告主張被告董事未盡善意努力(did not make a good faith effort)來遵守公司內部已建立的監督程序，惟法院認為就構成董事監督責任之主觀要件而言，原告必須證明被告惡意行為的存在，並提出具體事實主張董事有意識地怠於履行其監督義務；事實上，原告未能舉證證明被告董事知悉(knew)其等未適當監督公司的風險（亦即未證明間接故意(scienter)的存在），故不該當*Caremark*案及*Stone*案之審查標準的主觀要件¹⁹⁷。此外，*Stone*案亦適用於身負監督重任之獨立董事，對其監督義務之歸責審查標準也會有所不同：倘若獨立董事怠於履行監督義務係出於重大過失(gross negligence)，則尚未構成監督義務之違反；原告須舉證證明獨立董事系爭行為出於惡意（間接故意的不法心理狀態），始有監督義務違反之可能¹⁹⁸。論者亦表示，要求董事會監督企業風險管理之目的並非為了處罰董事會，毋寧是希望藉此要求董事會從事風險相關決策時能獲取一定的資訊。從而，以惡意此種較高的主觀要件作為違反監督義務之歸責基礎，即可能合適地在保護努力監督風險管理（但最終決策卻不佳）的董事會，以及處罰完全未盡監督義務的董事會之間取得平衡¹⁹⁹。

承前文「壹」導論之說明，企業內部自律機制中，風險管理的業務範圍雖包含法令遵循；惟觀察前開內部自律機制與董事監督義務此種外部他律機制之互動，當主張*Caremark*請求時，法令遵循與

197 See Harner, *supra* note 2, at 53-54.

198 Strine et al., *supra* note 171, at 693.

199 Harner, *supra* note 2, at 56. 參照德拉瓦州衡平法院前院長且現為紐約大學講座教授Allen在*Caremark*案判決中表示的意見，為滿足公司內部治理在「職權與責任」(authority and accountability)間達到平衡之需求，有必要對於監督義務違反時之責任成立與否建立一高檢驗標準，而不使董事動輒得咎。此種高責任標準不僅可讓適格的董事在本於善意履行義務的同時，更有機會來提供董事會的服務；亦能使董事監督行為在滿足權責相符且平衡的需求下，對公司營運產生正面效益，最終使股東集體受益。See Bainbridge et al., *supra* note 179, at 604.

風險管理間是否應或如何劃分其界限²⁰⁰？學者Bainbridge認為風險管理與法令遵循並無本質上的差異²⁰¹。首先，Bainbridge主張，將Caremark的主張限縮於法令遵循及會計遵循等機制，似非合理。蓋Caremark案雖指出法令遵循乃履行董事監督義務的內涵，但非屬唯一內涵，而只是踐行董事監督義務的內涵之一爾²⁰²。Bainbridge指出，Caremark案要求董事會應確保被提供足夠的資訊來履行其監督義務；該義務所指涉之範圍，不僅指法令及會計規範的遵循，實亦包含商業風險管理等業務執行層面²⁰³。其次，近來如COSO委員會所頒布之公司最佳實務守則將法令遵循歸類為風險管理的子項目之一，故董事被賦予監督風險管理之角色，與其被賦予監督法令及會計遵循的角色相類似²⁰⁴。再者，如前文「壹」導論所述，企業風險管理之範疇，應涵蓋組織內部所有程序，包含：辨識、衡量及管理諸如信用、市場、作業等風險²⁰⁵。亦即，董事會於風險管理中之角色，乃透過相關程序確保企業風險管理之有效性。可見，Caremark案要求董事會應建立並維持有效的通報系統，誠與董事會應確保有效之風險管理程序相似²⁰⁶。最後，風險管理失靈造成的問題與未遵循法令或會計規範所產生者差可比擬。重要的是，如同獨立董事或

200 應注意者，前文「壹」導論部分說明的是企業內部自律機制中，風險管理在概念上包括法令遵循與內控制度。相對而言，本文第「參」部分則討論企業外部他律機制中，董事監督義務之事後司法審查標準的射程範圍似應限於法令遵循，而不及於風險管理，法院始不會動輒以事後之明介入公司的商業決策。

201 Bainbridge, *supra* note 2, at 979.

202 *Id.* at 979-80.

203 *Id.* at 980. 有其他論者指出，美國模範商業公司法第8.30(b)條的官方注釋(the Official Comment to MBCA § 8.30(b))採類似見解，see BAUMAN, *supra* note 36, at 644 (“One part of a director’s duty of care involves oversight of the corporation’s business and affairs. Although recent cases have focused on the duty to create and monitor legal compliance programs, the duty of oversight applies to *every aspect of the corporation’s ongoing business.*”) (emphasis added).

204 Bainbridge, *supra* note 2, at 980.

205 Johnson, *supra* note 2, at 63.

206 *Id.*

大股東的監督、激勵性薪酬、外部審計、法令遵循機制及內控制度一樣，企業風險管理可被理解為董事會用來控制管理階層代理成本的一種公司治理機制²⁰⁷。據此，*Caremark*請求不僅適用於法令遵循、會計層面的內控制度，亦應適用於風險管理之有關層面²⁰⁸。總之，學者Bainbridge認為法院似應發展法令遵循層面外之修正版的*Caremark*請求審查標準，以此作為董事涉及違反風險監督義務之事後司法審查標準²⁰⁹。

然而，*Citigroup*案法院及學者Miller則持相反意見，認為過度擴張董事監督義務至風險管理的範疇，可能造成法院對公司涉及風險承擔之商業決策進行事後猜測，違反德拉瓦州對商業判斷法則之基本立場²¹⁰。以*AIG*案與*Citigroup*案為例，二案乍看之下可能均涉

207 *Id.* at 980-81. 關於如何透過各種企業內部自律機制、事前法律策略或事後法律策略之外部他律機制、以及其他非法律之市場上外部他律機制等公司治理機制的組合，以最小化管理階層的代理成本，亦請參見後文「參、六」的討論。

208 *Id.* at 981. 美國學者Johnson亦主張，州法院可藉由強化團體決策過程，改善風險管理之規範。進一步而言，法院可透過監督義務就判定是否構成「警示紅旗」的舉證責任標準，正視如前文「貳、三、(三)」所述之認知偏見及組織內互動等團體決策的固有缺陷，從而補強風險管理的監督義務。Johnson, *supra* note 2, at 107-08. 學者Harner也主張，董事會若未能建置有效的企業風險管理程序，其可能會在欠缺必要且適當資訊之情形下，批准公司的整體策略或作出其他重要決策。董事會在未合理地獲取資訊而作出與風險相關之決策的情形下，可能有害公司表現及最終的獲利。如此的風險管理失靈即可正當化董事會未建置並維持風險管理程序時應課予其違反注意義務的法律責任；換言之，透過法律責任可能發生的威脅，來影響其未來的行為。Harner, *supra* note 2, at 53, 55. 其他認為監督義務及違反時的責任應擴至監督商業風險層面的見解，*see, e.g.,* Pan, *supra* note 28, at 740; Nees, *supra* note 163, at 206 (“[D]irector oversight liability should be expanded beyond the original *Caremark* applications. Oversight liability for failing to monitor ‘business risks’ is an underdeveloped concept that has been met with hostility from the courts.”).

209 Bainbridge, *supra* note 2, at 968.

210 *See Citigroup*, 964 A.2d at 131; Miller, *supra* note 6, at 1156 (“[P]roposals to expand director oversight liability to police the problem of excessive risk taking by financial institutions ... are entirely impracticable. ... To have any meaningful effect on the outcome of cases, they would have to effect changes tantamount to repealing the business judgment rule.”). *See also* Miller, *supra* note 11, at 48 (“[B]ecause risk-

及*Caremark*案所衍生之董事監督義務的違反；事實上二者間有極大差異，不應一概而論。蓋*AIG*案之董事乃未能監督員工之詐欺及違法行為，此屬違反董事監督義務在傳統範疇上之內控制度及法令遵循部分²¹¹。然而，*Citigroup*案中之董事未能適當評估公司商業風險，乃未能監督企業風險管理，非屬*Caremark*案所處理之監督義務範疇，故不可以此追究董事個人責任；從而，董事監督義務不及於商業風險之監督²¹²。*Citigroup*案判決指出，若對於未能監督「過當」風險(“excessive” risk)的董事課予責任，而將監督義務之範圍予以擴張，則法院可能因而以事後之明介入評價公司的商業決策；此舉造成法院進行事後猜測，有違商業判斷法則²¹³。據此，董事監督義務及違反時之個人責任範圍（即使就專業董事而言），並不包含

management decisions are always business decisions, and because any business decision leading to losses for the company can be characterized as a risk-management failure, allowing courts to review risk-management decisions in oversight liability cases would, in effect, repeal the business judgment rule.”).

211 *AIG*, 965 A.2d at 798-99 (“[T]he Complaint states a breach of loyalty claim against Matthews and Tizzio for knowingly tolerating inadequate internal controls and knowingly failing to monitor their subordinates’ compliance with legal duties.”). See also *Citigroup*, 964 A.2d at 130 (“[T]he defendants in *AIG* allegedly failed to exercise reasonable oversight over pervasive *fraudulent* and *criminal* conduct. Indeed, the Court in *AIG* even stated that the complaint there supported the assertion that top AIG officials were leading a ‘criminal organization’ ...”).

212 See *COX & HAZEN*, *supra* note 178, at 156; Miller, *supra* note 6, at 1158 (“The oversight claim in *Citigroup*, however, was premised on a supposed failure by the board to detect and prevent not illegality or fraud by corporate employees but merely excessively risky business decisions by such employees. This theory was a somewhat novel application of *Caremark*.”) (footnote omitted). See also *Citigroup*, 964 A.2d at 130-31 (“Contrast the *AIG* claims with the claims in [*Citigroup*]. ... There are significant differences between failing to oversee employee fraudulent or criminal conduct and failing to recognize the extent of a Company’s business risk.”) (alteration in original).

213 *Id.* at 131. 學者Johnson雖如註208所述主張透過董事監督義務以強化風險管理，其亦自承若將監督義務擴至風險管理層面，則此種較重的責任標準可能有違商業判斷法則。然而，其仍主張有鑑於風險管理監督尤在具系統重要性之金融機構的營運模式中扮演關鍵角色，此即正當化在監督義務情形採取加強責任標準的作法。Johnson, *supra* note 2, at 108.

未能預測未來(predict the future)及未妥適評價商業風險(properly evaluate business risk)²¹⁴。

(四) *Citigroup* 案的政策分析

承上，學者Miller站在維持商業判斷法則的立場，支持*Citigroup*案法院的觀點，認為*Citigroup*案未將董事監督義務擴及至風險行為之監督，實不無道理。其提出精闢的見解而指出，風險管理並無預見未來的魔力。風險管理中風險經理人所使用之財務模型，通常係用來衡量資產投資組合中的市場及信用風險。實際了解此等模型後，即知財務模型產出之風險衡量結果必定內含典型的商業判斷。之所以如此，最重要的是因為這些模型試圖基於歷史資料預測未來結果。換言之，此等模型之預測能力係建立在未來發展於相關面向上將與過去事實相似的一般性假設；但實情常常不然。從而，風險管理決定必定是商業決定。設計並應用這些模型因而涉及行使相當的商業判斷，風險管理失靈一般而言應被視為商業判斷的失靈。商業人士即使本於善意且在獲取充足資訊下作出不善、甚至是災難性結果的商業決定，誠屬常見。這種情形不會因為此等人被稱為風險經理人而有所不同²¹⁵。再者，儘管風險管理有關模型具數學上的複雜性，其本質不可避免地必定是一種關於未來市場情況的商業判斷，而非一種避免損失的科學機制²¹⁶。從而，學者Miller主張，任何試圖將監督責任範圍擴大超出*Caremark*案關於內控制度及法令遵循之界限的舉動（或是容許法院在監督責任個案中審查風險管理決定），實際上就是否定商業判斷法則；此結果可能非眾人所企求者²¹⁷。循此，倘幾乎任何成果不佳之商業決定均可被定性為風險管理失靈，將監督責任擴至風險管理失靈即等同授權法院審查公

²¹⁴ *Citigroup*, 964 A.2d at 131.

²¹⁵ Miller, *supra* note 11, at 47-48, 120.

²¹⁶ *Id.* at 56.

²¹⁷ *Id.* at 48, 57.

司上上下下所作出之幾近所有的商業決定。若商業判斷法則具有效率，則擴張監督責任到風險管理失靈將會破壞此種效率²¹⁸。

此外，*Citigroup*案判決亦體現商業判斷法則不因社會不滿金融機構等其他民粹因素，而輕易受到撼動。誠如*Citigroup*案判決結論表示：法律賦予董事及經理人商業決策裁量權之目的，係為讓董事及經理人藉由承擔風險來長期地最大化股東價值，而無懼於在公司虧損的情形，致生個人究責的結果。金融海嘯期間，花旗集團特別因為次貸市場的問題而蒙受驚人虧損。吾人可理解投資人及社會大眾欲透過司法機制，找出應對其等損失負責之人。然而，此際實難以辨明欲找出負責之人的心態究為找出代罪羔羊來責難，抑或是迫使應負責之人為其不法行為負起責任²¹⁹。再如*Citigroup*案判決指出，吾人不應因自身蒙受損害致生責難他人的慾望，蓋此舉將使吾人對於法律上所欲保護之社會利益失焦²²⁰。此觀點背後之政策意涵係指，當公司面臨虧損時，股東不必然能任意主張董事應負個人責任²²¹。

五、從商業判斷法則之經濟分析思考董事監督義務的射程範圍

進一步從商業判斷法則的經濟分析角度以觀，為何美國法院縱使在如*Shlensky v. Wrigley*²²²等案之商業決定實不符常理的情形，仍不應對這些商業決定事後猜測？在*Shlensky v. Wrigley*乙案中，原告甚至不被允許提出證據以實其說。何以美國法院會在政策方向上採取商業判斷法則？首先，縱使無受託義務之法律規定，有鑑於已有

218 *Id.* at 47, 120-21.

219 *Citigroup*, 964 A.2d at 139.

220 *Id.*

221 *Id.*

222 *Shlensky v. Wrigley*, 237 N.E. 2d 776 (Ill. App. 1968). 關於該案的中文簡介，請參見邵慶平，論股份有限公司（法制）中所有與經營的合一與分離，月旦法學教室，34期，頁95-96（2005年）。

其他市場上及法律上用以降低代理成本的公司治理機制足以引導經理人作出合適行為，並監督管理階層；從而，在成本效益分析下，藉由受託義務相關訴訟所提供之額外遏阻力量的需求，即可能不大²²³。關於上述公司治理機制之例²²⁴：(1)薪酬合約可以提供經理人強烈誘因追求公司之利益；(2)當公司營運不佳時，其股價將下跌，導致該公司很容易成為可能之收購目標，此際惡意收購威脅所生之公司控制權市場即對公司代理人所為不利於本人的濫用職權行為加以約束；(3)產品市場上的競爭，以及公司破產之威脅也會抑制經理人在經營上的無能；(4)股東對董事之選任投票，與其等對於變更章程、合併、解散及公司重大資產讓售等重大變動事項之表決權，亦有助於使董事重視股東利益；(5)在閉鎖公司(close corporation)之情形，少數股東有權利收回出資而自公司外移，且其擁有解散公司之權，均會對經理人造成一定約束；(6)管理階層之經營是否欠缺效率，亦受到公司組織階級管理(managerial hierarchy)之檢驗，此等監督主要透過經理人或董事所運作的內部自律機制為之，有時亦會由外部董事或外部會計師引入外部監督力量；(7)公司經理人終其一生建立其廉潔、有效率之名聲，且此名譽在經理人市場中具有一定價值，若該經理人後來有不誠實或不盡心的情事發生，則其對名譽的投資將付諸流水；(8)資本市場（含直接及間接金融）一方面可能透過公司控制權市場使經理人有遭解職之危險，另一方面藉由減少經理

223 Hill & McDonnell, *supra* note 82, at 135-136. 另參見邵慶平，商業判斷原則的角色與適用——聯電案的延伸思考，科技法律評論，8卷1期，頁117（2011年）（「詳言之，運作良好的資本市場、人力市場以及董事薪酬與市場的連結，即會給予董事極大的壓力，力求增進公司的營運績效。因此，在一般情形下，從制度建構的成本效益來看，法律責任的賦予與法院介入的必要性顯然較低……。」）。亦請參見蔡昌憲，公司法上強行規定與任意規定間之權衡：以累積投票制、閉鎖公司制及新股認購權為例，臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁48-59（2004年）（介紹如公司控制權市場等抑制公司管理階層之代理成本的各法律上暨市場上公司治理機制）。

224 See Hill & McDonnell, *supra* note 82, at 135-36; RIBSTEIN & LETSOU, *supra* note 99, 360-61.

人所掌控之資產等方式，抑制經理人之濫權。

其次，受託義務在執行上所生之高訴訟成本，亦有助於解釋商業判斷法則之司法自我抑制的想法。由於大多公司董事會傾向於避免受託義務訴訟所生之麻煩、費用及負面的新聞報導，原告律師即使在訴訟不具相當實體理由的情形，也可能起訴以向董事會強索一定金額。若無商業判斷法則之適用，可能僅因最初本是個好想法之決定最後產生的成果不如人意，而使得經理人須負高額賠償責任；縱使在責任構成之可能性不大的其他情形，前開究責方式可能讓董事及經理人不當地對風險趨避(*unduly risk averse*)。不僅如此，在董事會決策雖在事前看來有其正當性，但決策後之事情發展不順的情形，法院（含陪審團）之事後諸葛偏見亦會增加責任產生的風險；從而，商業判斷法則有助於緩和前開事後諸葛偏見²²⁵。進一步言之，若管理階層很容易為了「不合理」(*unreasonable*)的交易遭究責，其將傾向於在作決策時過度小心，蓋其無法有效分散任職於特定公司之龐大的責任風險(*firm-specific liability risk*)。該公司的股東將不樂見這種過度小心的態度，蓋大部分股東在理論上就投資組合已有效分散特定企業風險，故寧可管理階層能不理會該種風險。總之，受託義務與違反時之責任帶有一定的成本（尤其可能造成經營上的風險趨避），對於商業交易過度密集之司法監督所生的成本，很可能超過其所帶來的效益²²⁶。

再者，曾宛如教授曾指明：「由於美國公司法制係以董事會優

225 Hill & McDonnell, *supra* note 82, at 136.

226 RIBSTEIN & LETSOU, *supra* note 99, 361, 387-88. 惟在公司經理人涉及利益衝突之案件（此際有違反忠實義務之虞）裡，何以其等不受商業判斷法則之保護？蓋在此類型的案件中，涉及利益衝突之人具有強烈誘因作出非基於公司最佳利益的決策。諸如激勵性薪酬(*incentive compensation*)或其他誘因機制面對利益衝突帶來之嚴重誘惑，常無法提供足夠之誘因以引導經理人作出合適的行為。又論者指出，在不法行為所生威脅特別高且司法干預之成本通常相對較低的情形，解決之道可能是經由明確規則之制訂直接對利益衝突交易加以設限。Hill & McDonnell, *supra* note 82, at 137.

位主義(director primacy)為政策，故賦予董事會極大之權限。……惟有對董事所為之商業決定為一定之尊重方可使體制運作順暢；美國法院遂有商業判斷法則之發明。」²²⁷詳言之，公開公司透過董事會將公司之決策及經營職權集中，藉此降低交易成本。一方面，法院無足夠的商業技能或資訊來擔任所謂的「超級董事」(super-directors)²²⁸；另方面，若法院對董事會決定之審查權限過大，則董事會之經營決策權實際上即被剝奪。職此，法院自動拒絕對未涉利益衝突之交易進行審查，即表示自我限制對董事會決定的審查範圍；從而，司法透過商業判斷法則保護將經營決策權限集中予董事會的法制設計²²⁹。換言之，誠如美國公司法學者Stephen Bainbridge指出，商業判斷法則的核心特徵實際上就是司法節制主義(judicial abstention doctrine)，亦即法院承認商業界有一塊司法不介入的自治領域²³⁰。

循上所述，本質上來看，商業判斷法則所蘊含之司法自我抑制理念即是一種在政府管制與自由市場間、公共利益與私法自治間的權衡結果²³¹。這種司法自我抑制的理念，亦與管制謙抑性(regulatory humility)²³²的主張不謀而合。申言之，至少在經濟分析

227 曾宛如，董事忠實義務於台灣實務上之實踐：相關判決之觀察，月旦民商法雜誌，29期，頁149-150（2010年）。

228 RIBSTEIN & LETSOU, *supra* note 99, at 387-88. See also Gagliardi v. TriFoods International, Inc., 683 A.2d 1049, 1052-53 (Del. Ch. 1996)（該案判決理由中即詳述商業判斷法則的政策基礎）。

229 Michael P. Dooley & Norman Veasey, *The Role of the Board in Derivative Litigation: Delaware Law and the Current ALI Proposals Compared*, 44 BUS. LAW. 503, 522 (1989).

230 Stephen M. Bainbridge, *The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine*, 57 VAND. L. REV. 83, 119 (2004). See also Stephen M. Bainbridge, *Director Primacy: The Means and Ends of Corporate Governance*, 97 NW. U. L. REV. 547 (2003).

231 See Lael Daniel Weinberger, *The Business Judgment Rule and Sphere Sovereignty*, 27 T.M. COOLEY L. REV. 279, 281 (2010).

232 蔡昌憲（註61），頁216；蔡昌憲（註24），頁325-326；蔡昌憲（註35），頁50；蔡昌憲，公司契約理論於我國之具體實踐——市場契約自由與國家法律干預間之權衡，法令月刊，56卷6期，頁44-45（2005年）。

的理論層面上，在權衡政府管制與自由市場孰為優先之際，對於市場的管制，即便明顯有可識別出之市場失靈的存在（如前述 *Shlensky v. Wrigley* 案中董事、經理人殊不合理的商業決定），政府是否介入管制，宜先考量管制手段本身所生之成本與效益。若事後司法審查帶來的成本（如造成經營階層決策上的風險趨避）顯高於其效益，此際或無管制干預的必要。這也可能是為何受託義務在美國法之傳統實踐上呈現「高度行為準則、低度審查準則」的現象²³³。甚且，如前文「貳、三、（三）」所述，德拉瓦州法院特別發展出本質為善意義務之董事監督義務，來解決組織偏見在董事會決策上造成之問題，以使得董事會運作不受到傾向於服從管理階層之偏見影響。惟若讓監督義務之射程範圍擴及至風險管理層面，則如前文「參、四、（四）」美國學者Miller所言，法院將對公司上上下下之種種決策介入更深，如此結果將有悖於前述經濟分析中支持商業判斷法則的理由。從而，例如在 *Caremark* 案所示涉及董事監督義務的情形，由於組織偏見造成負面影響之可能性甚低且容許董事會行使不受限制之裁量權的效益甚高，法院便僅訂出低度審查準則，只從事謙抑性管制²³⁴。綜上，本文亦贊同 *Citigroup* 案判決重申維護商業判斷法則的立場；該案判決同時展現法院保護董事作成合乎商業判斷法則前提的商業決定，且縱使該決定結果造成投資人受損害，董事無需動輒為其商業決策負擔個人責任。

六、風險治理問題之解決：公司治理機制間之互補合作

如下圖1所示，本文非主張單憑前文第「貳」部分以美國金融改革法為例的相關法令，或僅透過前文第「參」部分之董事監督義務的法律上外部他律機制，即足以完全解決風險治理問題。本文目的乃透過監督義務之司法審查演化，觀察公司治理機制中企業內部

233 邵慶平，公司法——組織與契約之間，頁346-350（2008年）。

234 See Hill & McDonnell, *supra* note 82, at 142.

自律機制（內控制度、法令遵循、風險管理）如何與法律上外部他律機制（事前法律策略、事後法律策略）進行互動；同時闡述公司治理機制中強制要求董事會獨立性等相關法令之事前法律策略，應如何與監督義務之事後法律策略進行權衡或搭配，始可謂「選擇適當之規範方法與手段……不至於過度增加公司遵循法規之成本或經營之難度，使公司治理制度能發揮最高效能。²³⁵」另如林仁光教授所主張，「公司治理制度推動之成功與否，成效是否彰顯，核心問題之癥結點在於經營者之誠信。……似乎目前所談論之公司治理制度，必須在經營者誠信經營並配合規範之前提下，始能發揮規範之功能。²³⁶」林教授亦指出：「內部控制制度之主要內容為企業管理之範疇，執行之成效須視經營者之誠信與專業而定。因此，若經營者有足夠之誠信與專業，即便無法律規範，亦能發揮良好之內部控制功能。但為防止經營者不誠信之情形發生，必須運用各種監控機制，包括內部監控機制與外部監控機制之配合，始能提升內部控制之成效。²³⁷」

本文亦循上述觀點，主張伴隨著公司經營權與所有權分離而生之代理成本問題，須透過企業內部自律機制、法律上外部他律機制、以及其他非法律之市場上外部他律機制等眾公司治理機制的組合，經由以下例示之每一治理機制的相互協調配合，來最化管理階層之代理成本：「組織形態之選擇」、「股東表決權與公司控制權市場」、「產品市場之競爭」、「資本市場之競爭與資本結構」、「公司表現與經理人報酬」、「經理人市場」、「公司階層制度及董事會」、「股權持有之結構」、「公司法及受託義務」等。並且，這些機制會彼此加強對方之功用，並補充其他機制可能有所遺漏之缺憾²³⁸。是

235 林仁光，論經營者誠信、內部控制、內部稽核制度與公司治理，月旦法學雜誌，106期，頁40（2004年）。

236 林仁光（註235），頁40。

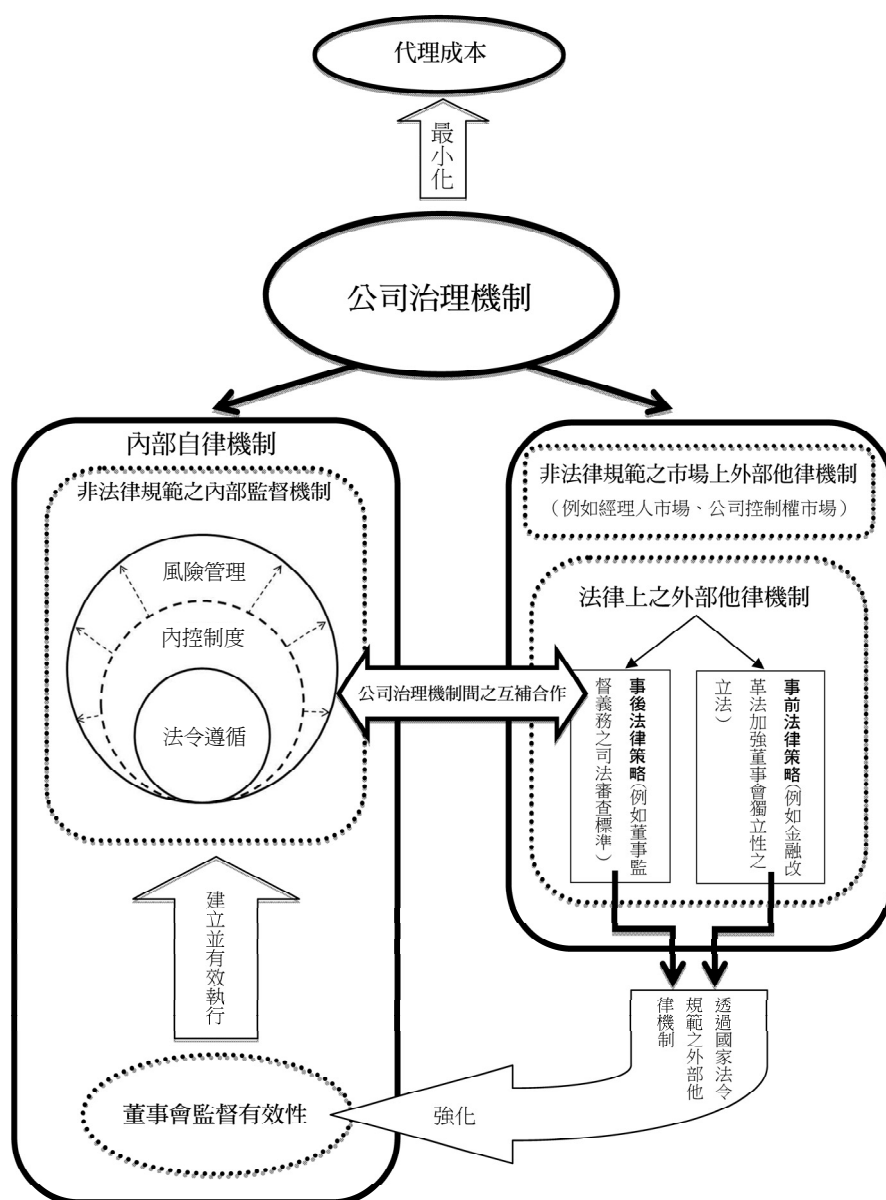
237 林仁光（註235），頁55。

238 See Butler & Ribstein, *supra* note 111, at 32. 亦參見蔡昌憲（註232），頁45。

故，就美國強化董事會風險管理功能之金融改革法相關管制措施而言，縱如前文「貳、三、(三)」所述，此種法律上外部他律機制因未充分反映董事會監督風險管理之決策過程中所存在的固有缺陷，而無法使風險管理得到有效執行。此難題正好指明，吾人無法僅仰賴企業內部自律機制²³⁹，抑或是只加強董事會獨立性或其他單一機制之法規範（屬事前法律策略之外部他律機制），即謂已找到促使風險管理獲得落實之萬靈丹。綜合而論，風險治理問題的解決之道，似應思考如何強化內部自律機制、事後法律策略（如董事監督義務）暨事前法律策略之法律上外部他律機制、以及非法律規範之市場上外部他律機制（例如透過經理人市場、公司控制權市場來監控經營者誠信）等各公司治理機制間的互補合作，或始能有效抑制管理階層的代理成本。

239 另如前所述，金融海嘯後提升風險管理有效性的關鍵之一，乃強化董事會本身監督風險管理的過程。美國有論者即透過組織行為理論(organizational behavioral theory)對團體決策(group decision making)的研究成果，主張為使董事在做決策時能充分獲得資訊，應進一步強化董事會的決策過程；惟其強調非法律規範之內部監督機制，並就此種企業運作實務改革提出具體建議，see Sharpe, *supra* note 23, at 309-12; Nicola Faith Sharpe, *Questioning Authority: Why Boards Do Not Control Managers and How a Better Board Process Can Help* 34-44 (Ill. Pub. Law Research Paper No. 11-14; Ill. Program in Law, Behavior and Social Sci. Paper No. LBSS12-02, 2012), available at <http://ssrn.com/abstract=2003010>.

圖1 風險治理問題之解決：
公司治理機制間之互補合作 (來源：本文作者)



肆、結論與啟示

本文藉由美國相關法令及普通法之董事監督義務等法律上外部他律機制，探究外部他律機制如何推動內部自律機制（內控制度、法令遵循及風險管理）的落實。具體而言，由前述美國近年來企業涉及風險管理等事前法律策略之外部法律規範的演變，可看出風險管理的重要性與日俱增；同時，董事於風險管理中所扮演的監督角色亦受重視。且關於另一屬事後法律策略之外部他律機制——美國法上董事監督義務，*Citigroup*案尤於金融海嘯的背景下，闡述董事監督義務、風險管理及商業判斷法則間之關聯性²⁴⁰。此外，雖有學者主張董事會若未執行有效的風險管理，似有違反其受託義務之虞²⁴¹；惟*Citigroup*案之判決顯示，法院謹守商業判斷法則之界線，作出董事監督義務內涵上不包括風險管理監督的結論，引起各界諸多討論。故未來美國董事監督義務之適用射程範圍，是否會進一步擴及至風險管理層面，仍有待觀察。一言以蔽之，本文贊同*Citigroup*案判決重申維護商業判斷法則的立場，並主張董事監督義務之事後司法審查標準，仍難以畢其功於一役地有效促成企業內部風險管理之達成；進一步言之，吾人難以單憑內部自律機制或外部他律機制之其中一項，即足以完全解決風險治理問題。從而，或仍

240 實際上，公司薪酬決策、董事監督功能及商業判斷法則間亦有密切關連。以美國2010年金融改革法之股東諮詢性投票規定為例，已有股東針對數家薪酬決定未獲過半數之股東諮詢性投票的公司董事會，提起代表訴訟。在這些訴訟中，有的法院支持以商業判斷法則駁回訴訟，有的則持反對立場。Kenneth B. Davis, Jr. & Keith L. Johnson, *Say on Pay Lawsuits - Is This Time Different?* 1 (Univ. of Wisconsin Legal Studies Research Paper No. 1182, 2012), available at <http://ssrn.com/abstract=1972406>. 由於美國股東及大眾逐漸施壓要求加強對董事會之管理階層薪酬安排的司法監督，故美國法院在面對此等壓力之際，未來可能會對股東諮詢性投票得到否決結果的案件採取較嚴格的審查標準。從而，為減少訴訟風險並取得投資人的長期支持，學者建議董事會改善管理階層薪酬的揭露、處理並回應正當的股東要求，同時注意如何將利益衝突及行為偏見自董事會的薪酬監督運作中移除。*Id.* at 17-18.

241 See, e.g., Harner, *supra* note 2, at 51.

應回歸思考強化各種公司治理機制間的互補合作，來最小化管理階層之代理成本。

吾人不僅應思考如何強化一國國內之各公司治理機制間之相互協調配合，以抑制代理成本問題。就比較公司治理而言，如何考量國外法律規範是否適於進行法律移植而成為國內法律上之外部他律機制（含事前與事後法律策略），以合宜地解決國內獨特公司治理環境所生之問題，亦具有現實上的重要性²⁴²。蓋公司治理與一國的經濟、文化及社會等背景密不可分，故難有可一體適用於各個不同國家內之在地董事會結構、股權結構及利益衝突的絕對標準²⁴³。舉例而言，國際規範趨勢上，以美國為例之主要國家立法者對於監督公司管理階層的重要機制，似有朝向以獨立董事為公司治理改革萬靈丹的趨勢發展²⁴⁴。惟亦有持不同意見之實證研究指出，過於強調董事獨立性可能不僅有損董事會的諮詢功能(advice function)，並且減低董事會的監督價值(the value of monitoring)²⁴⁵。據此，金融海嘯後我國所面臨公司治理問題的解決之道，並非盲目抄襲(blind copying)²⁴⁶地全盤移植外國法制，而是應考量國際規範趨勢如何與

242 See Donald C. Clarke, "Nothing But Wind"? *The Past and Future of Comparative Corporate Governance*, 59 AM. J. COMP. L. 75, 108-09 (2011).

243 See Daniel Johnson & Katarina Østergren, *The Movement Toward Independent Directors on Boards: A Comparative Analysis of Sweden and the UK*, 18 CORP. GOVERNANCE: AN INT'L REV. 527, 527, 535 (2010).

244 See Frederick Tung, *The Puzzle of Independent Directors: New Learning*, 91 B.U. L. REV. 1175, 1175-76 (2011) ("Recent governance reforms – the Sarbanes-Oxley Act and then the Dodd-Frank Act – reinforced this centrality of independent directors by mandating independent majorities on all public company boards and requiring that crucial board committees be comprised solely of independent directors.") (footnote omitted).

245 Øyvind Bøhren & R. Øystein Strøm, *Governance and Politics: Regulating Independence and Diversity in the Board Room*, 37 J. BUS. FIN. & ACCT. 1281, 1285 (2010).

246 CURTIS J. MILHAUPT & KATHARINA PISTOR, *LAW & CAPITALISM: WHAT CORPORATE CRISES REVEAL ABOUT LEGAL SYSTEMS AND ECONOMIC DEVELOPMENT AROUND THE WORLD* 210 (2008) ("[L]egal rules are sometimes borrowed in haste and without

我國在地制度環境的不同需求相調和²⁴⁷。此等在地化調整過程 (local adaptation)，或始為我國公司治理法制「成功地『移』入外國法律，並將其順利地『植』入實務運作」的關鍵²⁴⁸。

adequate preparation or familiarity ('blind copying').”)

247 參見王文字（註19），頁91（「公司法在市場競爭壓力下的『趨同』與『移植』已經成為不得不去正視的議題。如何借鏡他國法制、如何吸收調和外國法制進而形塑出在台灣能有效運作的模式？均是值得我國檢討、省思的課題。」）。See also Shahla F. Ali, *Globalization and Financial Dispute Resolution: Examining Areas of Convergence and Informed Divergence in Financial ADR* 8 (Univ. of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2012/012, 2012) (“The challenge at present, therefore, is to examine how global legal norms respond to national diversity while crossing international borders.”), available at <http://ssrn.com/abstract=1982315>.

248 王文字（註19），頁91。舉例言之，關於我國就董事監督義務進行法律移植之理念與在地化調整過程的配套等詳細探討，參見蔡昌憲（註98），頁1858-1878。

參考文獻

1. 中文部分

- Michel Crouhy、Dan Galai、Robert Mark合著，台灣金融研訓院編譯委員會譯（2004），風險管理，臺北：財團法人台灣金融研訓院。[Crouhy, Michel, Dan Galai, and Robert Mark. 2004. *Risk Management*. New York, NY: McGraw Hill.]
- Randy J. Holland著，陳春山等譯（2011），美國公司法——德拉瓦州公司法經典案例選集，臺北：新學林。
- 王文宇（2008），法律移植的契機與挑戰——以公司法的受託、注意與忠實義務為中心，月旦民商法雜誌，19期，頁81-91。
- （2008），公司法論，4版，臺北：元照。
- （2010），法學、經濟學與組織——兼論契約型與公司型共同基金組織（下），月旦法學雜誌，182期，頁5-18。
- 王志誠（2010），法令遵循主管制度之發展及挑戰，存款保險資訊季刊，23卷4期，頁92-154。
- 吳琮璫（2009），審計學：實務應用與法律觀點，4版，臺北：自版。
- 林仁光（2004），論經營者誠信、內部控制、內部稽核制度與公司治理，月旦法學雜誌，106期，頁39-55。
- 林國彬（2007），董事忠誠義務與司法審查標準之研究——以美國德拉瓦州公司法為主要範圍，政大法學評論，100期，頁135-214。
- 易明秋（2007），公司治理法制論，臺北：五南。
- 曾宛如（2010），董事忠實義務於台灣實務上之實踐——相關判決之觀察，月旦民商法雜誌，29期，頁145-156。
- 邵慶平（2005），論股份有限公司（法制）中所有與經營的合一與

分離，月旦法學教室，34期，頁88-96。

——（2007），董事受託義務內涵與類型的再思考——從監督義務與守法義務的比較研究出發，臺北大學法學論叢，66期，頁1-43。

——（2008），公司法——組織與契約之間，臺北：翰蘆。

——（2011），商業判斷原則的角色與適用——聯電案的延伸思考，科技法律評論，8卷1期，頁103-139。

殷若瑛（2006），修正後公開發行公司建立內部控制制度處理準則之內容，證券暨期貨月刊，24卷1期，頁31-37。

黃銘傑（2007），管窺力霸風暴中所暴露之公司治理與金融監理問題，月旦財經法雜誌，8期，頁1-28。

陳文彬（2009），企業內部控制評估，5版，臺北：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

陳錦隆（2011），公司治理與董事高權，臺北：台灣本土法學雜誌。

馮震宇（2008），企業當責與社會當責——當責不可忽略法令遵循，能力雜誌，626卷，頁57-65。

劉連煜（2002），論美國有關證券投資信託公司與證券投資顧問事業之規範對我國之啟示，月旦法學雜誌，80期，頁154-172。

熊秉元（2004），熊秉元漫步法律，臺北：時報文化。

蔡昌憲（2004），公司法上強行規定與任意規定間之權衡——以累積投票制、閉鎖公司至極新股認購權為例，臺灣大學法律學研究所碩士論文。

——（2005），公司契約理論於我國之具體實踐——市場契約自由與國家法律干預間之權衡，法令月刊，56卷6期，頁39-67。

——（2007），企業自治之逆流？——擺盪於強行規定與任意規定間之累積投票制，月旦財經法雜誌，8期，頁29-57。

——（2010），美國金融消費者保護規範之展望——以消費者金融保護局之創設為中心，月旦財經法雜誌，23期，頁187-

219。

—— (2012)，評我國強制設置薪酬委員會之立法政策——從經濟分析及美國金融改革法談起，中研院法學期刊，11期，頁249-340。

—— (2012)，從內控制度及風險管理之國際規範趨勢論我國的公司治理法制：兼論董事監督義務之法律移植，臺大法學論叢，41卷4期，頁1819-1896。

蕭巧玲 (2006)，法令遵循制度介紹，證券暨期貨月刊，24卷9期，頁36-49。

賴英照 (2011)，股市遊戲規則——最新證券交易法解析，2版，臺北：元照。

2. 西文部分

Ali, Shahla F. 2012. Globalization and Financial Dispute Resolution: Examining Areas of Convergence and Informed Divergence in Financial ADR. Working paper. University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2012/012. Available at <http://ssrn.com/abstract=1982315>.

Arlen, Jennifer. 2009. The Story of Allis-Chalmers, Caremark, and Stone: Directors' Evolving Duty to Monitor. Pp. 323-344 in *Corporate Law Stories*, edited by J. Mark Ramseyer. New York, NY: Foundation Press.

———. 2012. The Failure of the Organizational Sentencing Guidelines. *University of Miami Law Review* 66:321-362.

Bainbridge, Stephen M. 1993. Independent Directors and the ALI Corporate Governance Project. *George Washington Law Review* 61:1034-1083.

———. 2002. *Corporate Law and Economics*. New York, NY: Foundation Press.

- . 2003. Director Primacy: The Means and Ends of Corporate Governance. *Northwestern University Law Review* 97:547-606.
- . 2004. The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine. *Vanderbilt Law Review* 57:83-130.
- . 2007. *The Complete Guide to Sarbanes-Oxley: Understanding How Sarbanes-Oxley Affects Your Business*. Avon, MA: Adams Business.
- . 2008. *The New Corporate Governance in Theory and Practice*. New York, NY: Oxford University Press.
- Bainbridge, Stephen M., Star Lopez, and Benjamin Oklan. 2008. The Convergence of Good Faith and Oversight. *UCLA Law Review* 55:559-605.
- . 2009. *Corporate Law*. 2d ed. New York, NY: Foundation Press.
- . 2009. Caremark and Enterprise Risk Management. *Journal of Corporation Law* 34:967-990.
- . 2010. The Corporate Governance Provisions of Dodd-Frank. Working paper. UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper No. 10-14. Available at <http://ssrn.com/abstract=1698898>.
- . 2010. Corporate Governance and U.S. Capital Market Competitiveness. Working paper. UCLA School of Law, Law-Econ. Research Paper No. 10-13. Available at <http://ssrn.com/abstract=1696303>.
- . 2011. Dodd-Frank: Quack Federal Corporate Governance Round II. *Minnesota Law Review* 95:1779-1821.
- Bauman, Jeffrey D. 2010. *Corporations Law and Policy: Materials and Problems*. 7th ed. St. Paul, Minn.: West.
- Bebchuk, Lucian A., and Holger Spamann. 2010. Regulating Bankers' Pay. *Georgetown Law Journal* 98:247-287.
- Birdthistle, William A. 2010. Investment Indiscipline: A Behavioral

- Approach to Mutual Fund Jurisprudence. *University of Illinois Law Review* 2010:61-108.
- Blair, Margaret M., and Lynn A. Stout. 1999. A Team Production Theory of Corporate Law. *Virginia Law Review* 85:247-328.
- Böhren, Øyvind, and R. Øystein Strøm. 2010. Governance and Politics: Regulating Independence and Diversity in the Board Room. *Journal of Business Finance & Accounting* 37:1281-1308.
- Boyd, Roddy. 2011. *Fatal Risk: A Cautionary Tale of AIG's Corporate Suicide*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Brown, J. Robert, Jr., and Lisa L. Casey. 2011. *Corporate Governance: Cases and Materials*. New Providence, NJ: LexisNexis.
- Butler, Henry N., and Larry E. Ribstein. 1990. Opting Out of Fiduciary Duties: A Response to the Anti-Contractarians. *Washington Law Review* 65:1-72.
- Clarke, Donald C. 2011. "Nothing But Wind"? The Past and Future of Comparative Corporate Governance. *American Journal of Comparative Law* 59:75-110.
- Coffee, John C., Jr. 1989. The Mandatory/Enabling Balance in Corporate Law: An Essay on the Judicial Role. *Columbia Law Review* 89:1618-1691.
- Cox, James D., and Harry L. Munsinger. 1985. Bias in the Boardroom: Psychological Foundations and Legal Implications of Corporate Cohesion. *Law and Contemporary Problems* 48:83-135.
- Cox, James D., and Thomas Lee Hazen. 2010. *The Law of Corporations Vol. 2*. 3d ed. St. Paul, MN: Thomson/West.
- Davis, Kenneth B., Jr. 2005. Structural Bias, Special Litigation Committees, and the Vagaries of Director Independence. *Iowa Law Review* 90:1305-1360.
- Davis, Kenneth B., Jr., and Keith L. Johnson. 2011. Say on Pay Lawsuits

- Is This Time Different?. Working paper. Univ. of Wisconsin Legal Studies Research Paper No. 1182. Available at <http://ssrn.com/abstract=1972406>.
- Dooley, Michael P., and Norman Veasey. 1989. The Role of the Board in Derivative Litigation: Delaware Law and the Current ALI Proposals Compared. *Business Lawyer* 44:503-542.
- Easterbrook, Frank H., and Daniel R. Fischel. 1982. Corporate Control Transactions. *The Yale Law Journal* 91:698-737.
- . 1989. The Corporate Contract. *Columbia Law Review* 89:1416-1448.
- . 1991. *The Economic Structure of Corporate Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Goetz, Charles J., and Robert E. Scott. 1981. Principles of Relational Contract. *Virginia Law Review* 67:1089-1150.
- . 1985. The Limits of Expanded Choice: An Analysis of the Interactions between Express and Implied Contract Terms. *California Law Review* 73:261-322.
- Harner, Michelle M. 2010. Ignoring the Writing on the Wall: The Role of Enterprise Risk Management in the Economic Crisis. *Journal of Business & Technology Law* 5:45-58.
- Hart, Oliver. 1989. An Economist's Perspective on the Theory of the Firm. *Columbia Law Review* 89:1757-1774.
- Heremans, Dirk, and Katrien Bosquet. 2011. The Future of Law and Finance after the Financial Crisis: New Perspectives on Regulation and Corporate Governance for Banks. *University of Illinois Law Review* 2011:1551-1575.
- Hill, Claire A., and Brett H. McDonnell. 2007. Disney, Good Faith, and Structural Bias. *Journal of Corporation Law* 32:833-864.
- . 2012. Fiduciary Duties: The Emerging Jurisprudence. Pp. 133-

- 151 in *Research Handbook on the Economics of Corporate Law*, edited by Clair A. Hill and Bret H. McDonnell. Cheltenham: Edward Elgar.
- Johnson, Daniel, and Katarina Østergren. 2010. The Movement Toward Independent Directors on Boards: A Comparative Analysis of Sweden and the UK. *Corporate Governance: An International Review* 18:527-539.
- Johnson, Kristin N. 2011. Addressing Gaps in the Dodd-Frank Act: Directors' Risk Management Oversight Obligations. *University of Michigan Journal of Law Reform* 45:55-112.
- Jolls, Christine, Cass R. Sunstein, and Richard Thaler. 1998. A Behavioral Approach to Law and Economics. *Stanford Law Review* 50:1471-1550.
- Kamar, Ehud, Pinar Karaca-Mandic, and Eric Talley. 2009. Going-Private Decisions and the Sarbanes-Oxley Act of 2002: A Cross-Country Analysis. *Journal of Law, Economics, & Organization* 25:107-133.
- Kaplow, Louis. 1992. Rules Versus Standards: An Economic Analysis. *Duke Law Journal* 42:557-629.
- Kim, Hwa-Jin. 2011. Toward Transatlantic Convergence in Financial Regulation. Working Paper. Univ. of Mich. Law & Econ., Empirical Legal Studies Center Paper No. 11-004; Univ. of Mich. Pub. Law Working Paper No. 234. Available at <http://ssrn.com/abstract=1814122>.
- Kraakman, Reinier, Paul Davies, Henry Hansmann, Gerard Hertig, Klaus Hopt, Hideki Kanda, and Edward Rock. 2009. *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*. 2d ed. Oxford: Oxford University Press.
- Langevoort, Donald C. 2012. Behavioral Approaches to Corporate Law.

- Working paper. Georgetown Law and Economics Research Paper No. 12-015; Georgetown Public Law Research Paper No. 12-055. Available at <http://ssrn.com/abstract=2042009>.
- Loss, Louis, Joel Seligman, and Troy Paredes. 2011. *Fundamentals of Securities Regulation*. 5th ed. New York, NY: Wolters Kluwer Law & Business.
- Milhaupt, Curtis J., and Katharina Pistor. 2008. *Law & Capitalism: What Corporate Crises Reveal about Legal Systems and Economic Development around the World*. Chicago, Ill.: University of Chicago Press.
- Miller, Robert T. 2010. The Board's Duty to Monitor Risk after Citigroup. *University of Pennsylvania Journal of Business Law* 12:1153-1168.
- . 2010. Oversight Liability for Risk-Management Failures at Financial Firms. *Southern California Law Review* 84:47-123.
- Nees, Anne Tucker. 2010. Who's the Boss? Unmasking Oversight Liability within the Corporate Power Puzzle. *Delaware Journal of Corporate Law* 35:199-258.
- Page, Anthony. 2009. Unconscious Bias and the Limits of Director Independence. *University of Illinois Law Review* 2009:237-294.
- Palmiter, Alan R. 2011. *Securities Regulation*. 5th ed. New York, NY: Aspen.
- Pan, Eric J. 2009. A Board's Duty to Monitor. *New York Law School Law Review* 54:717-740.
- Pinto, Arthur R., and Douglas M. Branson. 2009. *Understanding Corporate Law*. 3d ed. New Providence, NJ: LexisNexis.
- Pirson, Michael, and Shann Turnbull. 2011. Corporate Governance, Risk Management and the Financial Crisis: An Information Processing View. *Corporate Governance: An International Review* 19:459-470.

- Posner, Richard A. 1998. Rational Choice, Behavioral Economics and the Law. *Stanford Law Review* 50:1551-1575.
- . 2009. Are American CEOs Overpaid, and, If So, What If Anything Should Be Done about It?. *Duke Law Journal* 58:1013-1047.
- . 2009. *A Failure of Capitalism: The Crisis of '08 and the Descent into Depression*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Ribstein, Larry E. 2010. Federal Misgovernance of Mutual Funds. Working Paper. Ill. Law & Econ. Research Paper No. LE10-018; Ill. Pub. Law Research Paper No. 10-06. Available at <http://ssrn.com/abstract=1661163>.
- Ribstein, Larry E., and Peter V. Letsou. 2003. *Business Associations*. 4th ed. Newark, NJ: LexisNexis.
- Romano, Roberta. 1986. A Comment on Information Overload, Cognitive Illusions and Their Implications for Public Policy. *Southern California Law Review* 59:313- 327.
- Shade, Joseph. 2010. *Business Association in a Nutshell*. 3d ed. St. Paul, MN: West.
- Sharpe, Nicola Faith 2010. Rethinking Board Function in the Wake of the 2008 Financial Crisis. *Journal of Business & Technology Law* 5:99-111.
- . 2011. The Cosmetic Independence of Corporate Boards. *Seattle University Law Review* 34:1435-1456.
- . 2012. Process Over Structure: An Organizational Behavior Approach to Improving Corporate Boards. *Southern California Law Review* 85:261-313.
- . 2012. Questioning Authority: Why Boards Do Not Control Managers and How a Better Board Process Can Help. Working

- Paper. Ill. Pub. Law Research Paper No. 11-14; Ill. Program in Law, Behavior and Social Sci. Paper No. LBSS12-02. Available at <http://ssrn.com/abstract=2003010>.
- Spulber, Daniel F. 2009. *The Theory of the Firm: Microeconomics with Endogenous Entrepreneurs, Firms, Markets, and Organizations*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Strine, Leo E., Jr., Lawrence A. Hamermesh, R. Franklin Balotti, and Jeffrey M. Gorris. 2010. Loyalty's Core Demand: The Defining Role of Good Faith in Corporation Law. *Georgetown Law Journal* 98:629-696.
- Thompson, Robert B. 2010. The Short But Interesting Life of Good Faith as an Independent Liability Rule. *New York Law School Law Review* 55:543-559.
- Tung, Frederick. 2011. The Puzzle of Independent Directors: New Learning. *Boston University Law Review* 91:1175-1190.
- Velasco, Julian. 2004. Structural Bias and the Need for Substantive Review. *Washington University Law Quarterly* 82:821-917.
- Walker, Rebecca. 2011. Board Oversight of a Compliance Program: The Implications of *Stone v. Ritter*. *Practising Law Institute/Corporate Law and Practice Course Handbook Series* 1910:143-149.
- Weinberger, Lael Daniel. 2010. The Business Judgment Rule and Sphere Sovereignty. *Thomas M. Cooley Law Review* 27:279-319.
- Williamson, Oliver E. 1985. *The Economic Institutions of Capitalism*. New York, NY: The Free Press.
- Wilson, Gregory P. 2011. *Managing to the New Regulatory Reality: Doing Business under the Dodd-Frank Act*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Winter, Jaap W. 2011. The Financial Crisis: Does Good Corporate Governance Matter and How to Achieve it? Working paper. DSF

Policy Paper No. 14. Available at <http://ssrn.com/abstract=1972057>.
Yang, Jingjing, Jing Chi, and Martin Young. 2011. A Review of
Corporate Governance in China. *Asian-Pacific Economic Literature*
25:15-28.